

論違憲審查之程序理性*

——從Dworkin獨白取向之裁判理論到Habermas之 司法法律論辯理論

李俊增**

摘 要

本文之核心問題是司法違憲審查過程經常涉及準立法活動，如何可能獲致調和並同時確保法定定性與正確性（正義）之理性裁判。Dworkin之裁判理論尋求由Rawls之反思均衡方法，來調和並確保實證法傳統與正義，從而為理性裁判奠基。本文批判Dworkin此一理論主張，並嘗試藉由Habermas之程序主義途徑（並作部分之理論修正），來探討司法違憲審查之程序理性，從而為憲法裁判實體內容之理性奠基。為此，本文指出須採Habermas之程序主義途徑重新理解法定定性與正確性（正義）概念，藉由司法法律論辯以調和二者。此外，並應相對化Habermas有關證立論辯與適用論辯之區分，使司法違憲審查過程之法律論辯以某種方式納入證立論辯要素。據此，司法違憲審查為一多重之法律對話論辯過程，而為此種多重法律論辯結構支配之違憲審查過程所蘊含之程序理性，即確保了憲法裁判實體內容之理性。

* 投稿日：2014年1月9日；接受刊登日：2014年8月28日。〔責任校對：洪瑋辰〕。

作者非常感謝三位匿名審查人提供之寶貴意見，讓作者有機會重新檢視、修正及補充。當然，一切文責仍由作者自負。

** 國立高雄大學政治法律學系副教授。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/51100251.pdf>。



關鍵詞：司法法律論辯、程序理性、司法違憲審查、憲法解釋、哈伯瑪斯、德沃金。

目 次

壹、前言	三、嚴格區分規範之證立與規範之適用及其修正
貳、Dworkin裁判理論之問題點	肆、違憲審查過程蘊含之證立論辯要素與多重司法法律論辯之形構
一、反思均衡方法獲致理性裁判之問題點	一、違憲審查程序蘊含之證立論辯要素——大法官與民主政治部門及公共領域間對話論辯結構之揭示
二、反思均衡方法之獨白式取向的問題點	二、大法官合議所形成之對話論辯結構
參、Habermas之司法法律論辯理論	伍、結論
一、對裁判正確性之程序主義的了解	
二、對法安定性之程序主義的了解	

壹、前言

本文認為司法違憲審查中大法官解釋憲法經常涉及準立法活動，為避免憲法裁判陷於決斷主義之非理性危機，因此嘗試藉由當代重要之法律哲學家Jürgen Habermas的程序主義途徑（並作成部分之理論修正），來探討司法違憲審查之程序理性，從而為憲法裁判實體內容本身之理性奠基。

按由於憲法規範本身具高度抽象、不確定性，長久以來憲法裁判即受到是否尚屬法解釋適用之司法活動的質疑，且不分美國、歐

陸或我國均有重量級學者為此撰文探討。我國吳庚大法官曾區分完整法規範與不完整法規範，前者包括構成要件及法定效果，其中一項或兩項均缺者即是不完整法規範，他並指出憲法條文常屬不完整法規範，是各國憲法的通則，而以我國憲法最為顯著¹。換言之，憲法中多為抽象之原則性宣示，而非具有構成要件可供涵攝之概念，法律是否牴觸憲法因此經常存有高度爭議。從而早在威瑪憲法時期Carl Schmitt即指出在解決這類爭議，乃是將有疑義之規範內容除去其疑義，確定規範之內容，此一除去憲法內容之不確定，本質上是法律內容之決定，故而是一種立法，甚至是憲法制定，而不是司法²。

時至今日，在司法違憲審查制度源起之美國，知名學者Frank I. Michelman同樣指摘如何適用憲法之問題無法與憲法內容是什麼的問題明白分開，適用憲法之同時即在進行創造憲法，而且是以一絕非不重要的方式在進行創造³。即使在司法違憲審查之正當性甚少受到質疑之德國，知名學者Ernst-Wolfgang Böckenföde亦從區分「解釋」與「具體化」之活動本質角度，強調對憲法內容（特別是基本權）的確定本身包含了原則，這些原則之特性即在於其所包容的廣度與內容上的不確定性。從而必須仰賴憲法法院的填充與具體化。憲法法院權限之行使因此已無可避免脫離（預設一客觀法上之

-
- 1 吳庚，憲法的解釋與適用，頁566-567（2003年）。不過，王鵬翔認為基本權規定可重構為「若……，則……」之表述形式而具有「構成要件—法律效果」的結構，而我國憲法第23條此一對基本權之概括限制條款則相當於以負面構成要件形式出現的例外條款。換言之，帶限制條款之基本權規範之形式具規則特徵。不過，此一重構模式中由於限制條款包含了比例原則之要求，在認定限制條款是否滿足時，必須與相衝突之原則進行衡量。因此基本權規範之形式最多只是一種「不完全規則」，或者可稱為「規則／原則結合模式」。王鵬翔，論基本權的規範結構，臺大法學論叢，34卷2期，頁31、39-41（2004年）。
 - 2 Carl Schmitt 著，川北洋太郎譯，憲法の番人，頁63（1989年）。另見黃舒芃，德國法上違憲審查權限爭議的歷史軌跡：從H. Kelsen與C. Schmitt的辯論談起，政治與社會哲學評論，5期，頁141-142（2003年）。
 - 3 FRANK I. MICHELMAN, BRENNAN AND DEMOCRACY 21 (1999).

「適用標準」、並受此「客觀標準」拘束的)「法適用」,而趨近於(講求創造性的、相對不受拘束的)「法制訂」之性質⁴。

然而不僅如此,在美國激進之批判法學派甚至針對聯邦最高法院與民主立法者間之權限分際此一具高度爭議性問題,批判指謫前者之活動已導致「法即政治」⁵。在德國同樣有學者指出憲法解釋每每被視為「法」與「政治」活動交錯融合下的產物,從而無法透過釐清「法」與「政治」的分際,為憲法法院權力行使劃定界線⁶。

上述學者之論點突顯了由於憲法規定內容(尤其基本權)之高度不確定性、開放性與具備原則性格,已對司法違憲審查權限之行使是否尚屬依法解釋構成重大挑戰,法解釋與法創造之界線在此已趨於高度模糊化;另一方面,這也意味憲法解釋流於主觀、恣意的高度可能性。然而,這些問題並不僅來自憲法內容之高度不確定性,更重要的是對於憲法基本權之解釋往往涉及重大道德爭議。蓋如Ronald Dworkin所言,憲法基本權條款通常使用極為抽象之道德語言,因此使得在憲法案件中,常無法僅僅依據相關文本,以道德中立的方式來作出裁判;反之,必須涉及道德判斷。Dworkin甚至認為美國司法違憲審查實務之主流,大法官之憲法解釋均涉及道德判斷。值得注意的是,這種認為憲法解釋涉及道德判斷的觀點並不限於美國。在德國憲法法院於Lüth案中亦明白指出「基本法無意作為價值中立的秩序,……其在基本權利章中同時建立一套客觀價值秩序」⁷。我國大法官亦指出基本權及自由民主憲政秩序表彰了

4 黃舒芃,憲法解釋的「法適用」性格:從德國公法上法學方法論傳統對「法適用」與「法制訂」的區分探討聯邦憲法法院解釋活動的本質,政大法學評論,81期,頁84-85(2004年)。

5 Mark V. Tushnet, *Critical Legal Studies: A Political History*, 100 YALE L.J. 1515, 1517-18 (1991).

6 黃舒芃(註4),頁55。

7 BVerfG 7, 198 (204 f.).

憲法基本價值，憲法解釋涉及價值之判斷。例如：司法院釋字第392號解釋理由書中強調「從歷史上探知憲法規範性的意義固有其必要；但憲法規定本身之作用及其所負之使命，則不能不從整體法秩序中為價值之判斷，並藉此為一符合此項價值秩序之決定」。司法院釋字585、601號等解釋更明白表示大法官解釋憲法之目的係在維護「人民基本權利及自由民主憲政秩序等憲法基本價值」。凡此均意味無論德國憲法法院或我國大法官之憲法解釋均涉及對憲法基本權條款所蘊含之價值的詮釋，均涉及價值判斷。德國憲法法院雖曰基本法在基本權利章建立了一套「客觀價值秩序」，惟究諸實際，各國憲法基本權條款通常反映制憲當時不同黨派所持之不同的價值體系與世界觀，日後國會立法時大多數重要意識形態的衝突即表現為關於權利之性質與適用之衝突⁸。何況隨著戰後社會更趨多元，各種對於善的生活之理想，如女性主義、社群主義、文化多元主義等紛紛興起，其各自對於基本權蘊含之基本價值的理解往往因此存在高度歧見、爭議。換言之，憲法基本權條款所表彰之道德原則或基本價值，並非理所當然即是一套「客觀」的「秩序」，毋寧其中潛藏各種相衝突詮釋之可能性，大法官憲法解釋之際，極易訴諸一己主觀之價值信念，而流於恣意擅斷。其結果導致憲法裁判之作成並非理性的展現，反之，不過是大法官據其權力對於價值所作決斷性的選擇，從而陷於Schmitt決斷主義之非理性的危機⁹。

8 ALEC STONE SWEET, GOVERNING WITH JUDGES: CONSTITUTIONAL POLITICS IN EUROPE 102 (2000).

9 黃舒芃從德國法觀點，指出基於「法適用」的本質，任何對憲法規範「具體化」的結果，都必須能夠找到憲法上的依據，並能與整個憲法規範體系取得協調與一致性。而法釋義學所提供的論理結構與實體內容，即扮演了拘束憲法法院具體化活動的角色。他並引 Robert Alexy 之主張表示，對憲法法院而言，一個重要任務即在於透過判決的累積，在「價值秩序」所提供的基礎上，不斷發展作為解釋與適用依據的法釋義學結構與內容。並據此駁斥上文 Böckenföde 有關「具體化」之活動已導致憲法法院權限之行使趨近於「法制訂」性質之論點。參黃舒芃（註4），頁88-97。換言之，德國法強調透過法釋義學之發展、建立而對憲法法院之權限行使發揮拘束的功能。甚至認為「價值秩序」發揮了「在法適用的傳統底下，提供憲法法院進行解釋與適用之出發點」的功能。惟

面對憲法之高度不確定性、具備原則性格以及憲法解釋涉及道德（或價值）判斷，本文立場認為必須坦誠司法違憲審查過程中大法官解釋憲法經常涉及準立法活動，法解釋與法創造之界限已趨高度模糊（尤其在所謂之困難案件）。但另一方面，面對導致憲法解釋淪為權力政治之結果，陷於決斷主義之非理性危機的批判，本文則持不同見解。本文企圖從程序主義的角度論證指出大法官職司憲法解釋仍能獲致理性之裁判。按理性裁判之基礎涉及兩項條件：法安定性與正義（正確性），雖然這兩項條件存在著內部緊張，但一項理性之裁判必須調和並同時確保這兩項條件。本文所採程序主義之途徑係立足於Jürgen Habermas之司法法律論辯理論，並作適度之修正（本文反對Habermas嚴格區分規範之證立與規範之適用的論點，強調二者之區分趨於相對化），從而據此探討司法違憲審查所涉及之多重對話論辯過程，並重構這些過程之溝通預設與條件，揭示為論辯結構所支配之司法違憲審查程序蘊含之程序理性，而程序之理性即確保了憲法裁判實體結果之理性。當然，在此必須注意的是，依Habermas之程序主義的觀點，理性裁判之兩項條件：法安定性與正義（正確性）均被重新理解而有了新的意義。

相對於Habermas之程序主義途徑，另一位法哲學家Dworkin則嘗試從不同途徑來調和法安定性與正義，以建構其理性裁判之理論。其實，大體而言，Dworkin之司法裁判（或精確而言，整全法

究諸實際，Bernhard Schlink 卻指出德國憲法之動態發展乃取決於憲法法院所面對裁判之個案以及不同法官之政治傾向等。他指出：「我們可以看到憲法法院之政治鐘擺從一邊盪到另一邊。因此，有 1990 年代初期關於言論自由之自由主義傾向判決，以及在 1970 年代關於憲法財產權條款之福利國傾向的解釋。……（憲法法院）所採之路線完全取決於其面臨了什麼樣的個案或難題，以及法官之政治傾向」。他並認為憲法法院之所以視基本權為一價值，純粹是因為當時所面對之個案需要一個新的概念。See Bernhard Schlink, *The Dynamics of Constitutional Adjudication*, in HABERMAS ON LAWS AND DEMOCRACY 371, 374, 376 (Michel Rosenfeld & Andrew Arato eds., 1998)。倘 Schlink 所論為真，則德國憲法法院裁判之際，法官同樣易帶入其主觀之價值信念。

之法律解釋)理論與Habermas之司法法律論辯理論存在諸多相同之處，惟卻在一關鍵之處分道揚鑣。此一關鍵的歧異點即構成了本文核心論旨之基礎。按Dworkin與Habermas二人同屬本務論者。二人並同樣承認法律體系之複雜性，認為法律除了規則之外，尚包含原則與政策。Dworkin堅持權利是王牌，強調旨在落實政治道德權利之原則論證優先於政策論證。與此類似，Habermas強調經由審議民主立法程序，道德理由進入了法律，他並堅持道德理由優先於倫理理由或實用的理由，權利優先於善，原則論證優先於政策論證。再者，Habermas認為法律解釋應對既存之法律實踐作「批判地撥用」、進行「理性重構」或「重構評估」。就這一點而言，Habermas之法律解釋方法與Dworkin之建構解釋方法相當接近¹⁰。最後，二人均堅持理性裁判是可能的，並強調理性之裁判必須調和並確保法安定性與正義。

Habermas與Dworkin之司法裁判理論雖然有上述相同之處，但有關如何調和法安定性與正義（正確性），卻各自依循不同之途徑，而形成有意義之對比。依後者，法官係藉由John Rawls式之反思均衡方法以調和法安定性與正義；但依前者，則係藉由程序主義取向之司法法律論辯（亦即藉由程序理性之實踐）來調和法安定性與正義。前一途徑強調法官個人之哲學反思，為獨白模式，而後一途徑則係取向於程序主義之對話論辯模式¹¹。此外，必須注意的

10 不過，必須注意的是，Dworkin之建構解釋法蘊含以John Rawls式之反思均衡方法來尋求實證法傳統與正義間之調和均衡，則與Habermas之程序主義的理論途徑大相逕庭（詳下述）。

11 三位審查人對於本文將Dworkin與Habermas司法裁判理論，區分為獨白模式（或實體理論）與程序主義模式以形成對比，多所質疑，認為Dworkin之理論並未忽略程序面向；而Habermas之理論也不全然是程序性的。本文對於審查人上述論點，基本上同意。不過，從認識論角度言，Dworkin之理論雖未忽略程序面向，但對於程序在正確答案之獲致上究竟居於何種地位，卻不曾有理論上之系統性的闡釋；反之，他理論的核心仍在於論述如何經由獨白式之個人哲學反思以追求符合正義之正確的結果。然而，如果個人之自我反思已足以確保獲致正確答案之可能性，則Dworkin理論之程序面向在其認識論上即變得無關

是，如前所述，在Habermas之程序主義的觀點下，法安定性與正義（正確性）均作了重新的理解，從而也與Dworkin有關這些概念的理解有異。由於存在上述之同異點，因此在探討Habermas之司法法律論辯理論前，本文將先對Dworkin之裁判理論進行分析、批判，以與前者形成對照，突顯前者之優點與特出之處。據此，本文核心論旨之一即在於強調司法解釋活動並非係法官個人之哲學反思，不應狹隘地僅限於對法體系之解讀；反之，司法裁判必須滿足司法法律論辯之程序條件的要求，法官必須動態地、轉變性地調和裁判過程中多重、不同的觀點，才可能確保裁判之理性。本文有關違憲審查之程序理性的討論即立基於此項論旨之上。

本文之進行分為下面三大部分：一、反省、批判Dworkin裁判理論之問題。本文將批判強調Dworkin企圖藉由Rawls反思均衡方法而獲致滿足整全性要求之健全的道德判斷，並調和實證法傳統與道德健全性之理論途徑並不成功。此外，亦將指出反思均衡方法之獨白取向的問題點。二、探討、分析Habermas之司法法律論辯理論，指出其如何藉由程序主義途徑（程序理性）來調和並確保法安定性與裁判之正確性（正義）。值得注意的是，Habermas在闡論其裁判理論之際，嚴格區分立法與司法；或者以Habermas之說法，區分證立論辯與適用論辯，並認法官之裁判活動僅涉及後者，從而其司法法律論辯的進行僅存在於當事人之間以及法官與當事人之間。Habermas此一嚴格區分證立論辯與適用論辯受到諸多批判。尤其重

緊要，或者至少意義不明。（詳見第貳節二、）。相對於此，Habermas 強調的是面對世界去魅化，社會秩序之宗教與形而上的支持已遭破壞，因此符合正義之正確答案僅能經由程序取向之對話論辯而獲致。至於審查人之一指出 Habermas 所提出之溝通預設與程序條件均蘊含了「實質的倫理或規範意涵」，這並無法否認。畢竟一個不具實質規範意涵之前提的程序甚難想像。但重點是其論辯倫理原則——(D)原則，並非係從更高層級之實質性格律（axiom）推導而出，而是奠基在形式一語用學之分析上（詳見第參節一、）。基於上述理由，本文認為固無法完全否認 Dworkin 理論之程序面向或 Habermas 理論之實質面向，但二人之理論取向明顯不同，而形成有意義之對照。

要的是，本文將指出Habermas此一論點與其法律論辯理論之核心論旨：事實性與有效性間存在著緊張關係，相互矛盾。惟Habermas在闡論法律實質化所造成之衝擊及因應之道時，卻又修正傾向於權力分立之相對化，強調司法之適用論辯必須為取自證立論辯之要素所補充。不過，Habermas對於如何補充卻未深論。如上述，本文認為法官進行司法違憲審查經常涉及準立法活動，因此本文接受Habermas有關證立論辯與適用論辯區分相對化的修正，並且主張只有司法違憲審查過程之法律論辯以某種方式納入證立論辯要素以為補充，方能夠說明涉及準立法活動之司法違憲審查之程序理性。

三、進一步解釋分析在符合司法獨立之憲法要求下，違憲審查程序必須納入證立論辯要素作為補充之深層意涵。並對現代民主憲政國家司法違憲審查制度及其實踐進行重構，揭示違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間之連結形式，指出此一程序包含有大法官與民主政治部門及公共領域間之對話論辯結構。藉此顯示違憲審查程序納入了證立論辯要素作為補充，某種意義上實現了法律論辯理論有關規範證立理想上的要求。不僅如此，本文亦將重構分析指出職司憲法裁判之機關普遍以人數頗高之大法官組成，以及大法官評議以自由、平等的方式進行等制度及實踐，其背後隱含大法官間之司法對話論辯過程接近Habermas之「理想言說情境」。據此，本文認為司法違憲審查涉及多重之對話論辯，並不限於法官與當事人間以及當事人間之對話論辯。而為此多重論辯結構支配之司法違憲審查過程所蘊含之程序理性，即確保了實體憲法裁判趨近於理性之可能性。藉此本文希望從多少內在於違憲審查制度及實踐的觀點，掌握司法違憲審查過程尚待挖掘之程序理性，而為實體憲法裁判之理性奠基。

貳、Dworkin裁判理論之問題點

本節首先指出由於Dworkin視法律為解釋性概念，所以在他看來，憲法與其他法律並無本質上的差別。從而憲法解釋方法與一般法律解釋方法亦無不同，均採建構解釋法。建構解釋法藉Rawls式之反思均衡方法以獲致滿足整全性要求之健全的道德判斷，並調和實證法傳統與道德健全性。本文將指出Dworkin之理論途徑欲達此一目的，所遭遇理論上之困難。此外，並進一步指出Dworkin此一理論途徑為獨白取向，以及獨白取向之法律解釋方法的問題點。

一、反思均衡方法獲致理性裁判之問題點

Dworkin指出（美國）憲法之權利條款使用了、「極為空泛、抽象之語言」，表現為「非常一般性之原則」¹²，並承認這導致了「非常大之法律與政治爭議」¹³。但爭議的來源不只來自於權利條款之「極為抽象」的語言，更重要的是，Dworkin認為這些語言是「道德語言」、這些原則是「抽象的道德原則」¹⁴。Dworkin強調法官應視憲法權利條款為「表達抽象之道德要求，這些要求僅能透過道德判斷而適用於個案」；換言之，必須對這些抽象條款作「道德解讀」：必須立於它們訴諸了道德原則之瞭解而解釋、適用這些條款¹⁵。然而，他亦坦承道德解讀將政治道德帶入了憲法之核心，而「政治道德本質上是不確定且具爭議性的」¹⁶。

值得注意的是，依Dworkin之理論，法官裁判時須作道德判斷並不限於解釋、適用憲法之情形。由於Dworkin視法律為解釋的概

12 RONALD DWORKIN, FREEDOM'S LAW: THE MORAL READING OF THE AMERICAN CONSTITUTION 2, 7, 9 (1996).

13 RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 133 (1978).

14 DWORKIN, *supra* note 12, at 7.

15 *Id.* at 2.

16 *Id.*

念，這使得法官在解釋任何法律實踐均須進行道德判斷。質言之，Dworkin指出對於法律實踐應採取解釋性態度；此一態度假設法律實踐蘊含某種本旨或價值或執行著某項原則，且實踐之要求應反映此項本旨，而作瞭解、適用或修正、延伸¹⁷。對於Dworkin而言，法律實踐，無論憲法或其他制定法或判決先例均是正義、公平與正當法律程序這些原則持續開展之政治敘事¹⁸。所以無論憲法或其他法律本即同樣具有對解釋性爭議開放之不確定面向，乃是各種哲學爭議的焦點。法官解釋憲法或其他法律，進行論證時即是面對哲學問題，必然涉及政治／道德判斷；即是在尋求政治／道德理論¹⁹。這也就是為什麼Dworkin強調法官係哲學家；任何法官之意見本身均是法律哲學，只是此一哲學通常被隱藏在由引證與事實臚列所支配之論證下²⁰。

換言之，由於Dworkin視法律為解釋的概念，所以在他看來，

17 RONALD DWORKIN, *LAW'S EMPIRE* 47 (1986)。本文有關 *Law's Empire* 之譯文，均參考李冠宜之譯作：Ronald Dworkin 著，李冠宜譯，*法律帝國*（2002年）。

18 *Id.* at 225.

19 Nigel E. Simmonds, *Imperial Visions and Mundane Practices*, 46 *CAMBRIDGE L.J.* 465, 466-69 (1987)。在「認真看待權利」乙書中，Dworkin 區分容易案件與困難案件，並認為容易案件裁判依據規則即可作成，但在困難案件則須訴諸原則或政策。但「法律帝國」中，Dworkin 在指出法律是解釋概念的同時，並指出裁判容易案件與裁判困難案件之方法並無不同：「Hercules 不須對於困難案件採一種方法，而對於容易案件又採另一種方法」See DWORKIN, *supra* note 17, at 354。「整全法既說明與證立困難案件也說明與證立容易案件；……就整全法而言，容易案件僅係困難案件之特案」See also DWORKIN, *supra* note 17, at 266。據此，學者認為即使是 H.L.A. Hart 所謂之規則的核心部分也是解釋性的，從而也是不確定的。法官裁判時所建構之法律理論（政治／道德理論）尚要求特定個案應以與既存法律規則之核心部分不同的方式而裁判，該看似「核心」的部分即須退讓。See Lawrence B. Solum, *The Unity of Interpretation*, 90 *B.U. L. REV.* 551, 554-55, 558, 566 (2010)。不僅如此，Dworkin 指出法律是解釋的概念，強調法律實踐蘊含某種本旨或價值之外，如後述，他並認為應對於法律概念採用建構性解釋，建構出有關特定法律概念之解釋，該解釋即展現了吾人認為該概念所擁有的價值。Dworkin 後來並坦承「解釋概念之概念分析本身因此即是道德理論中之一種操作」See RONALD DWORKIN, *JUSTICE FOR HEDGEHOGS* 166-68 (2011)。

20 DWORKIN, *supra* note 17, at 90.

憲法與其他法律並無本質上差別。Dworkin也未發展出不同於一般法律解釋理論之憲法解釋理論。雖然他也曾指出相較於其他法律解釋，憲法解釋中哲學性爭議更顯著地浮出檯面，而且這是一種基礎性的、更深層的哲學爭議²¹。

無論如何，憲法作為解釋的概念，本身即具不確定面向，加上憲法權利條款高度空泛而抽象，其蘊含之政治道德且在本質上具更深層的哲學爭議，從而大法官對於權利條款作道德解讀如何可能作成理性之裁判，即受到強烈質疑。批判者認為道德解讀賦予了大法官將一己之道德信念強加於公眾之上的絕對權力；它模糊了法律與道德之重要區別，使得法律成了某一特定時期之大法官對於道德原則偶然持有之信念的展現；有論者甚至認為道德解讀使得大法官不是在解釋既有之憲法，而是創造新的憲法²²。

面對這些批判，Dworkin並不諱言道德解讀使得大法官一己關於政治道德之觀點影響了其憲法裁判²³。但Dworkin強調語言、歷史與憲法整全性（constitutional integrity）嚴格地限制了道德解讀給予每個大法官之自由空間²⁴；「我們的憲法是法律，就如同所有法律一般，它緊緊固定在歷史、實踐與整全性之上」²⁵。他並強調道德解讀即是在發現符合（fit）憲法整體歷史記錄之憲法道德原則的最佳具體內容（conception）²⁶，形成一融貫的憲法道德；解釋憲法與解釋其他制定法一樣，即在使憲法整體實踐儘可能地成為最佳²⁷。換言之，法官之憲法裁判必須與經理性重構之既存之憲法實踐史相符合，此一對既存之憲法實踐史的重構，須使憲法整體實踐可

21 *Id.* at 380.

22 DWORKIN, *supra* note 12, at 2, 4.

23 *Id.* at 3-4.

24 *Id.* at 10.

25 *Id.* at 11.

26 *Id.*

27 DWORKIN, *supra* note 17, at 397.

以在一融貫之憲法道德的基礎上被證立。據此，在Dworkin看來，理性之憲法裁判必須調和實證法傳統與最佳道德證立（或道德健全性（soundness）），以同時確保法安定性與（廣義的）正義。而他提出之調和方法即Rawls式之反思均衡方法。

進一步言之，Dworkin指出解釋者依建構解釋法，著眼於解釋者所賦予法律實踐之目的、價值或原則與被解釋之實踐間的互動以達於均衡，從而形成對於既存法律實踐之理性重構的法律理論；他強調建構性之解釋企圖在其所發現之法律實踐與對該實踐之最佳證立間達成均衡²⁸。他甚至明確表示可以將解釋的不同階段總結為：解釋係尋求在關於一社會實踐之前解釋的說明與對該實踐適當的證立二者間建立均衡。他並強調在此借用了Rawls所謂「反思均衡」之「均衡」²⁹。藉由反思均衡方法調和實證法實踐之傳統與道德健全性，即構成對解釋者主觀之道德信念以制衡，並能夠獲致同時確保法安定性與（廣義的）正義之理性裁判。Andrei Marmor對此並進一步深入說明，他指出Dworkin之解釋理論假設文本之同一性（identity）、符合性與健全性三項觀念之間是循環關係；裁判時建構法律理論之目的，係為了獲致同一性、符合性與健全性三者間之反思均衡。解釋過程必須在這三者之間來回不斷比較檢視、修正，經由三者相互調適，以使三者彼此能夠相互支持³⁰。換言之，同一

28 *Id.* at 90.

29 *Id.* at 424.

30 Andrei Marmor, *Coherence, Holism, and Interpretation: The Epistemic Foundations of Dworkin's Legal Theory*, 10 LAW & PHIL. 383, 398, 404 (1991). See also JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 21 (1971). 另 David Ingram 亦認對 Dworkin 最佳的理解，係將之視為是藉由 Rawls 式之反思均衡方法來調和平衡實證傳統與哲學理性。See DAVID INGRAM, REASON, HISTORY AND POLITICS: THE COMMUNITARIAN GROUNDS OF LEGITIMATION IN MODERN AGE 255 (1995)。此外，必須注意的是，在「認真看待權利」乙書中，符合性是一門檻，法官裁判時所建構之法律理論必須滿足符合性此一門檻標準，如果有多個法律理論通過此一門檻，再依健全性來排序何者最佳。See DWORKIN, *supra* note 13, at 340-41. 但「法律帝國」乙書則指出符合性係提供粗略的門檻要件，於依健全性檢視多個滿足符合性要件

性、符合性與健全性三者間之關係係反思均衡，係一融貫的關係。特別值得注意的是，Marmor強調此融貫關係不只要求這三者間之相互支持，更要求此一關係內部必須足夠複雜³¹。換言之，唯有同一性、符合性、健全性三者間之關係既彼此相互支持且足夠複雜，方足以構成對解釋者之背景道德信念有意義之限制。

Marmor對於同一性、符合性與健全性三者之融貫關係必須足夠複雜的強調，來自Dworkin對Stanley Fish之批判的回應。按如前所述，Dworkin指出法官之道德價值信念須符合前解釋階段之過去的法律實踐，亦即符合憲法、其他制定法、司法裁判等文本，從而受其限制，但Fish卻指出Dworkin所謂前解釋階段之文本並非獨立於解釋者、自我顯示之未經琢磨的事實（brute fact）；反之，它僅能以業經解釋的形式呈現，因此文本並無法制衡解釋³²。針對Fish之批判，Dworkin坦承沒有獨立於解釋者、獨立於理論之文本事實。但另一方面，他又否認文本因此即必然無法限制解釋者之主觀（道德）價值信念。他認為文本是否能夠限制解釋的關鍵在於解釋性判斷之內部結構化與複雜性。Dworkin並且強調法官裁判所建構之法律理論即包括了關於符合性與道德價值二組不同信念，這正顯示了其解釋性判斷之複雜性。在這二組不同信念之互動中，解釋者可以發現對於解釋之限制與標準，且此一互動也顯示出解釋性判斷此一行為之本質環境³³。Dworkin後來又再一次明確地指出任何解釋者如果真係在進行解釋而不是創造，則解釋者之信念間實際上必

之法律理倫何者最佳時，符合性的問題會再次出現，從而須在符合性與健全性間尋求「一般性均衡」。See also DWORKIN, *supra* note 17, at 256.

31 Marmor, *supra* note 30, at 398, 404-06.

32 Stanley Fish, *Working on the Chain Gang: Interpretation in the Law and in Literary Criticism*, in THE POLITICS OF INTERPRETATION 271, 274 (W. J. T. Mitchell ed., 1983).

33 Ronald Dworkin, *My Reply to Stanley Fish (and Walter Benn Michaels): Please Don't Talk about Objectivity Any More*, in THE POLITICS OF INTERPRETATION 287, 288, 292-93 (W. J. T. Mitchell ed., 1983).

須彼此制衡，而這又依賴其相關意見整體之複雜性與結構³⁴。換言之，Dworkin坦承文本之理論依賴性，但將有關對解釋限制之理論負擔從文本同一性之面向轉移至符合性面向。他強調符合性面向與道德健全性面向係屬不同種類，而指出符合性面向具充分的複雜性，此一複雜性之假設並說明了對於解釋之限制的可能性。不過，Marmor卻指出Dworkin之解釋理論中不僅文本之同一性依賴道德健全性面向，對於符合性之信念亦同樣依賴構成健全性面向之評價性判斷。從而傷害了其理論中之複雜性，其所謂對於解釋之有意義的限制也因此變得可疑。

Marmor此一質疑借助Nigel E. Simmonds 對於Dworkin之批判。Simmonds強調在每一特定領域符合必須達到如何的程度才是充分這個問題，決定於在該領域中區分解釋與創造之所以重要的理由。就司法裁判領域而言，為什麼法官建構之法律理論必須是對於過去法律實踐之解釋？法官為什麼不可以自行創造未符合過去法律實踐之法律概念？或者更直接地說，為什麼法官必須依據法律理論，而不得以正義理論為基礎而裁判？Simmonds指出Dworkin之回答即是這是整全法的要求。整全法解釋了法官之角色與義務是解釋而不是創造；整全法提供了解釋須符合過去法律實踐達於如何程度的標準，而整全法乃係實質的價值判斷³⁵。換言之，對於符合性之信念依賴著構成道德健全性面向之評價性判斷。據此，Marmor指出吾人有關文本之同一性及符合性之信念均依賴道德實質證立。如此一來，Dworkin解釋理論中之複雜性觀念勢將受重創。蓋複雜性觀念不僅須包括量的標準，尚須包括質的標準；即一項足夠複雜的理論不僅須包含足夠數量之信念，這些信念尚須如Dworkin所言，係屬不同種類、層次之信念。但Dworkin解釋理論中解釋之主要的二項要素卻均來自同一評價性判斷：整全性，然則Dworkin所謂不

³⁴ DWORKIN, *supra* note 17, at 66, 257.

³⁵ Simmonds, *supra* note 19, at 478-79.

同種類、層次之信念彼此相互制衡將變得可疑，解釋性判斷之複雜性也因此不保³⁶。從而亦將無法對解釋以有意義的方式作限制，其反思均衡之操作能否獲致客觀之證立令人不能無疑。

此外，值得注意的是，反思均衡在道德哲學中作為證立道德原則之方法，係在尋求特定個人所持慎思之道德判斷（*considered moral judgments*）與道德原則間之融貫。惟由於個人所持道德判斷可能只是偏見，只是該個人之階級、文化背景、自利或歷史事件之反映罷了。為解決此一難題，所尋求之反思均衡必須是廣的反思均衡；亦即不僅須尋求慎思的道德判斷與道德原則間之融貫，道德判斷且須尋求與相關之背景理論（包括各種業已發展之道德理論與非道德理論如社會學、經濟學、心理學等）相融貫。過程中個人所持任何慎思之道德判斷必須開放受相關背景理論之批判、檢視，並均可以被修正、甚至放棄。透過此種將道德判斷暴露於批判與修正之過程，方可能使反思均衡之操作獲致客觀之證立³⁷。然而，對於法律實踐進行建構解釋時，倘如上述係在尋求同一性、符合性與道德健全性三者間之反思均衡，或者在尋求解釋者所發現之法律實踐與該實踐之最佳證立間達成反思均衡，則必受限於符合性此一要求，以致不容許超過某種比例之法律實踐被修正或廢棄，但這樣一來即違反了尋求反思均衡之際任何事物潛在上均可修正的要求，而導致無法達成反思均衡³⁸。

總之，Dworkin之建構解釋法企圖藉反思均衡方法以調和並確

36 Marmor, *supra* note 30, at 410-11.

37 RAWLS, *supra* note 30, at 49; NORMAN DANIELS, JUSTICE AND JUSTIFICATION: REFLECTIVE EQUILIBRIUM IN THEORY AND PRACTICE 21-28 (1996); Norman Daniels, *Reflective Equilibrium*, Stanford Encyclopedia of Philosophy (Apr. 28, 2003), <http://plato.stanford.edu/entries/reflective-equilibrium/>.

38 Larry Alexander & Ken Kress, *Against Legal Principles*, 82 IOWA L. REV. 739, 766 (1997); Cass R. Sunstein, *On Analogical Reasoning*, 106 HARV. L. REV. 741, 778, 783 (1993).

保實證法傳統與道德健全性並不成功。或者由於文本之同一性與符合性之信念均依賴構成道德健全性面向之評價性判斷，傷害了解釋性判斷之複雜性，無法對解釋者之背景道德構成有意義限制，以避免法律解釋質變為法律創造；或者由於遷就符合性此一要求，而難以獲致解釋之道德健全性。然而，困難不限於此。在Dworkin之解釋理論中，道德判斷之健全性或真值，係取決於它滿足整全性要求，但這能否達成同樣有其問題。進一步言之，Dworkin不僅將文本之同一性、符合性與道德健全性三者間理解為一反思均衡，一融貫的關係，他並強調各種政治道德原則間之融貫關係。他指出整全性要求法官儘可能假設法律為一組融貫之有關正義、公平、正當法律程序之原則所結構化，它要求法官執行這組融貫的原則於當前之個案中³⁹；應注意的是，整全性要求的不只是個別不同法律本身之融貫性，而是要求所有這些法律表達一組融貫的原則。整全性要求法官須對於法律帝國整體賦予融貫的結構⁴⁰。

不過，Dworkin之融貫論並非要求強的一元融貫性；亦即這些政治道德原則並非係從其中一項原則推導而出，或從具統一性精神（unified spirit）之少數原則推導而出⁴¹。反之，Dworkin指出這些原則是「獨立」且「相競爭」的⁴²。另一方面，他同時堅稱這些原則固然是相競爭的，但不能認為它們彼此間具深層敵對、不可解之哲學性矛盾。當然二項相競爭的原則在某些個案中可能會相衝突；亦即，個案中解釋者對於法律實踐之建構性解釋，對於法律實踐所建構之原則，可能有多項均能通過符合性門檻，但其彼此間卻相互衝

39 DWORKIN, *supra* note 17, at 243.

40 *Id.* at 273。有關 Dworkin 之整全性或融貫性概念，國內學者王鵬翔有深入而精要之闡釋，參王鵬翔，法律、融貫性與權威，政治與社會哲學評論，24 期，頁 31-33（2008 年）。

41 See JOSEPH RAZ, ETHICS IN THE PUBLIC DOMAIN: ESSAYS IN THE MORALITY OF LAW AND POLITICS 290 (1994).

42 DWORKIN, *supra* note 17, at 268-69.

突。此時由於整全性要求解釋法律實踐時應視之為持續開展之政治敘事，所以法官此時即須以最佳方式持續這整體故事，並使得這二項原則在這故事中均有確定位置；換言之，在任何對法律實踐之一般性解釋中不能完全否認其中任何一項原則，否則即違反整全性。從而雖然有時候個案中原則之間會相衝突，但在同一一般性解釋中它們仍舒適的相處一起⁴³。

個案中二項原則衝突，固然必須尋求更一般性的解釋以避免完全否認任何一項原則，但如何解決其間的衝突呢？Dworkin指出必須訴諸更上位的原則，來決定何種衝突解決方式從政治道德觀點能夠以最佳的角度顯示該社群之整體的法律紀錄；Dworkin強調法官這時的決定反映的不只是他對於正義與公平的意見，必須同時反映其關於這些衝突原則應如何解決之更上位的信念⁴⁴。他指出此時「融貫性要求某種非恣意的、有關這些衝突原則間之排序優先性（priority）或衡量（weighing）或調和（accommodation）之計劃，亦即在更深的政治道德層次反映其各自根源之計劃」⁴⁵。

換言之，面對個案中原則間之衝突，融貫性要求必須訴諸更上位的原則，來決定應以排序優先、衡量或調和等方式解決衝突，從而依更深層次之政治道德觀點能提供法律實踐整體最佳道德證立，形成一組融貫之原則架構。對此，Simmonds批判指出此一論點意味解釋須依賴更深、更基本層次之評價性標準，而這將導致陷入無窮回溯之邏輯困境的危險。質言之，解釋須使法律實踐盡可能成為最佳道德實踐，這將使得（廣義的）正義問題在解釋中扮演重要角色，但正義問題同樣是解釋性問題。那麼應如何選擇對於正義信念之最佳解釋呢？Dworkin認此只能訴諸人性或自我理論⁴⁶。但自我

43 *Id.* at 269-87.

44 *Id.* at 256.

45 *Id.* at 269.

46 *Id.* at 425.

或人性問題是否也是解釋性問題？Simmonds質疑Dworkin的回答如果是肯定，則將陷入無窮回溯之邏輯困境；但如果否定，則他恣意的區分了何者是、何者不是解釋性問題⁴⁷。無論如何，這都將導致是否存在所謂「最佳道德證立」成為問題，從而法官是否真的係依據其所相信具道德健全性面向之道德判斷而非主觀之擅斷來做裁判，即成大問題。

針對Simmonds之批判，Marmor善意的指出或許Simmonds誤解了Dworkin之理論，或許Dworkin之理論非屬直線式結構，而屬循環結構；法律、正義與自我等不同知識領域間之關係並非化約關係，而應理解為係一反思均衡，係一融貫關係。據此，倘自我理論能與其他知識領域相一致，即能提供解釋之道德健全性，從而沒有必要再進一步訴諸更上位之評價性標準以滿足健全性之要求⁴⁸。

然則，依Dworkin之法律解釋理論，個案中原則間衝突之解決，即須以反思均衡方法探求在該個案中哪一原則能與上位之政治道德原則以及更上位之自我理論相融貫；且須使另一相競爭原則亦保有確定位置，不致被完全否認⁴⁹。據此，為解決個案原則間之衝

47 Simmonds, *supra* note 19, at 471-72.

48 Marmor, *supra* note 30, at 407-08. 當然此一反思均衡之循環關係為上述之複雜性理論所支持。

49 必須注意的是，在此 Dworkin 雖然指出整全性要求法官儘可能假設法律為一組融貫之原則所結構化，但他認為在個案中原則間會發生衝突；而融貫性要求應藉由建構這些相衝突原則間之排序優先性、衡量或調和之計劃來解決此一衝突，如此一來在個案中或者某一原則優先被適用，或者尋找出一調和方式來適用這些原則，只是不管那一種方式均不可完全否認任一原則。據此實可認定，Dworkin 應係承認個案中原則間「真的」會發生衝突，且融貫性固要求應尋求方法解決此一衝突，但他對融貫要求的程度僅限於在個案裁判中不可「完全否認」另一相衝突原則。但之後的著作中他的立場似有所改變。他認為價值（包括政治價值）間之衝突只是表面的，而且可經由概念解釋使價值間彼此整合、相互支持，從而並無真的價值衝突。2006 年之 JUSTICE IN ROBES 一書中，Dworkin 強調政治價值，（即政治道德原則）例如自由、平等只是初步看似衝突，但可以使用反思均衡方法，建構消弭衝突之有關這些政治價值之具體內涵，並使之彼此「相互增強」。他甚至指出必須建構這些政治價值之具體內

突，須尋求融貫的對象不可謂不廣。從而Marmor亦不免擔心地指出「所賦予融貫之角色含蓋愈廣，則否認其實現之可能性將愈看似有理」⁵⁰。換言之，能否使不同之道德判斷間達成某種反思均衡，而滿足整全性之要求，以獲致符合道德健全性之正確裁判，仍不無疑問。

此外，尚須一提的是，法官在個案中尋求原則間衝突的解決，經常會受到法典範的引導。然而，法典範卻潛藏質變為意識型態的危機，從而危及裁判之道德健全性。進一步言之，Habermas指出法官不僅是立於法律文本之脈絡，而且是居於當時社會主流之前了解的視角來進行法律解釋。換言之，指涉特定社會意像或社會願景之當時社會關於法律的典範式了解會提供法官法律解釋以觀點，會引導法官。從而一項法典範通常即蘊含於範例性之法院裁判且通常即

涵，成為涵蓋性更大之價值結構的一部分；此價值結構不僅將政治結構與道德，且與倫理相連結。See RONALD DWORKIN, JUSTICE IN ROBES 159-62 (2006)。2011 年之新作 JUSTICE FOR HEDGEHOGS 一書中，Dworkin 更提出價值統一論。他強調所有價值概念，包括道德、倫理與法律概念均是解釋性的。而且均可藉由解釋這些概念，以最佳闡釋其蘊含之價值，從而顯示這些價值是「彼此整合」且「相互支持」的。換言之，藉由發展對這些價值概念之最佳解釋，將可發現所有價值衝突只是表面上的。See DWORKIN, *supra* note 19, at 1, 107-08, 203-04, 414-15。他明確表示：

在此真的存在衝突？……如果我要維持在本書有關價值統一之主要聲稱，我必須否定此一衝突。因為我的聲稱不只是我們能夠使我們不同之道德判斷達成某種反思均衡——即使我們承認我們的價值相衝突，藉由在特殊個案中對價值採取某種優先排序，或採取某組原則以裁決衝突，我們仍然能夠達成此。我想要防衛更具野心的聲稱，亦即沒有真正的價值衝突其需要此種裁決。(DWORKIN, *supra* note 19, at 119)

在當代多元主義社會中，Dworkin 此種價值統一論的主張確實甚具野心。尤其其他的主張不只限於政治道德原則間彼此能夠整合，尚包括與具脈絡依賴性之倫理間亦能夠使之相互增強，其野心不可謂不大。當然，也引起論者之強烈質疑。See Dale Smith, *Law, Justice and the Unity of Value*, 32 O.J.L.S. 383, 394-97 (2012); Don Herzog, *Cute Prickly Critter with Presbyopia*, 110 MICH. L. REV. 953, 964-65 (2012).

⁵⁰ Marmor, *supra* note 30, at 409.

表現出法官之隱含的社會意象⁵¹。法典範會將相競爭之原則依該典範所內含之有關規範適用之特定情境的一般化描述來予以排序。據此，法官以整全性作為裁判原則，尋求個案中相衝突之原則，經由優先排序、衡量或調和來解決衝突以形成一組融貫之原則架構時，通常即是在法典範所決定之背景了解的範圍內作判斷決定。Habermas強調對於法律之典範式的了解穩定化了司法解釋，從而有助於法安定性（詳下述）。然而，值得注意的是，法典範會經由專業上與司法制度上對於法律解釋的壟斷，僅允許根據一己之標準作內部修正，而自我穩定化，從而可能僵化成為「封閉的」典範，無視於環境激進的變化，排除對於原則或權利之不同解釋，而質變為意識型態⁵²。如此一來，法官在僵固法典範引導下所作之融貫解釋不過是一種意識型態地扭曲之投射。另一方面，它仍然會面臨另一法典範下針對相同案件所作同樣融貫之解釋的競爭挑戰⁵³。為消除法典範意識型態罩頂的疑慮，並從相競爭的法典範中作正確的選擇決定，Habermas指出法官必須走出獨白式理論建構之孤立獨處，視其建構性解釋基本上是為公民之公共溝通所支持之共同事業，以使不同的法典範間能夠進行對話論辯取向之競爭⁵⁴（詳下述）。

綜上所述，Dworkin之解釋理論企圖藉反思均衡方法而獲致滿足整全性要求之健全的道德判斷，以及調和並確保實證法實踐之傳統與道德健全性，能否成功；其是否足以有意義地制衡法官個人之

51 JÜRGEN HABERMAS, BETWEEN FACTS AND NORMS: CONTRIBUTIONS TO A DISCOURSE THEORY OF LAW AND DEMOCRACY 388-89, 392 (William Rehg trans., MIT Press 1996) (1992).

52 HABERMAS, *supra* note 51, at 221.

53 *Id.* at 221.

54 *Id.* at 221-22。Habermas 此一立場亦來自他認為有關法典範何者正確之爭議，本質上是政治爭議；在憲政民主國家中，此一爭議攸關所有參與者。因此有關對法體系之正確的典範性了解之爭議，不能僅由隔離於政治場域外之法官的專業論辯來作決定，法官並不能使用專業權威強加其觀點於其他人民之上，公民公眾必須親自判斷法官之觀點是否具說服力；公民公眾最終必須能夠決定引導法律實踐之特定的法典範是否具規範上的可接受性。

主觀的道德信念並獲致兼具法安定性與（廣義的）正義之理性裁判，非無疑問。就憲法解釋而言，如Dworkin自己所承認的，由於憲法條文使用之語言抽象、空泛程度遠高於其他制定法，加上論證中哲學爭議明顯浮出，且涉及者係屬基礎性之哲學爭議，如此一來運用Dworkin之解釋方法能否獲致兼具法安定性與（廣義的）正義之理性的憲法裁判，即更加令人質疑。

二、反思均衡方法之獨白式取向的問題點

如上述，Dworkin之建構解釋方法著眼的只是解釋者藉反思以使一己之不同道德判斷達成均衡，只是解釋者所賦予法律實踐之目的與被解釋之實踐間的互動以達於均衡；換言之，反思均衡方法乃是獨白取向的，它強調的是法官面對法律實踐應採取「自我反思」的態度⁵⁵。從而，Michelman尖銳地批判指出Dworkin之整全法欠缺的是對話，他所創造之理想上的法官是一「孤獨者。他太過英雄化，他的敘述性建構是獨白式的。除了書本，他不必與任何人交談對話。他不會遭遇論戰。不用面對不同意見。沒有其他意見會動搖他。沒有任何對話者會挑戰破壞其經驗與觀點之不可避免的孤立性」⁵⁶。

值得注意的是，上述法律解釋理論蘊含獨白式之取向，與Dworkin堅信遵循其理論能有意義地制衡解釋者個人道德判斷之恣意性（即法官能夠建構法律理論以獲致理性之裁判）密切相關。這也正是他為什麼強調法官依賴一己之信念，其意義係依賴該信念之真理性或健全性⁵⁷。然而，如上文所論，藉反思均衡方法而獲致滿足整全性要求之健全的道德判斷，或調和實證法傳統與道德健全

⁵⁵ DWORKIN, *supra* note 17, at 413.

⁵⁶ Frank I. Michelman, *The Supreme Court 1985 Term—Foreword: Traces of Self-Government*, 100 HARV. L. REV. 4, 76 (1986).

⁵⁷ DWORKIN, *supra* note 17, at 124.

性，仍有其困難處。在此情況下，Dworkin堅持，面對歧見，法官裁判之作成僅須依賴一己負責地自我反思所作之道德判斷，無庸多所考慮並回應不同意見，無庸與他人進行對話論辯，這種觀點無疑使得法官之決定更易流於恣意的選擇。畢竟對話論辯程序之意義主要即在要求法官聽取與一己相歧異（甚至是自己極為排斥）之意見，並重新反思省視一己之判斷，作出回應——無論是加強其論證以駁斥他者之意見、或修正乃至放棄一己之意見並重新建構其論證，凡此均是對法官個人之道德判斷課予了獨立於法官本人之外的重要外在限制，從而亦賦予了法官裁判一定之客觀性。上文亦指出為避免法官進行法律解釋時所依賴法典範變質成為意識型態，必須放棄獨白取向之司法裁判概念。

從另一角度觀之，Dworkin之法律理論主要視法律為表達政治社群之共同願景或理想，但Dworkin有關法律實踐之後設理論卻蘊含著私取向之新教徒主義。進一步言之，Dworkin提出整全性作為政治社群之政治理想與政治德性，這意味政治社群成員接受他們「係依共同原則，而不僅是政治妥協中產生之規則，而受統治」⁵⁸。政治社群成員（不限於官員，尚包括公民）因此相互負有義務，藉由遵行（廣義的）正義原則來維持社群共同生活之整全性，實現對每一個成員平等關懷與尊重之原則⁵⁹。Gerald J. Postema因此指出整全性要求社群成員（包括官員與公民）以過去之共同決定與實踐為始點，尋求融貫之「共同、公共的」（廣義之）正義原則，從而整全性所要求之實踐反思論證也應是共同的、公共的行為⁶⁰。Postema表示Dworkin所理解之整全性既與（廣義的）正義深深緊密連結，而正義之本質是政治的；即正義僅能共同地追求達成。正義不只是

⁵⁸ *Id.* at 211.

⁵⁹ *Id.* at 195-215.

⁶⁰ Gerald J. Postema, *Integrity: Justice in Workclothes*, in DWORKIN AND HIS CRITICS: WITH REPLIES BY DWORKIN 291, 294-95 (Justine Burley ed., 2004).

共善，且是共同的產物，共同審議、共同行動的產物⁶¹。然而，Dworkin一方面固然強調去思索、想像社群對原則的公共許諾是什麼不只是法官的責任，且是每一位公民之責任；彷彿承認實踐是共同的。但另一方面，卻指出此一想像、思索整全性之要求的態度係「新教徒態度（protestant attitude）」⁶²。Postema據此批判指出，Dworkin有關社會實踐之解釋的後設理論完全不要求注意其他參與者之解釋行為。此中存在的是Dworkin理論強烈的「新教徒主義」。亦即每一位參與者係經由對實踐之私的解釋而接近有關法律是什麼的真理；參與者過著宛如每一個人有各自一己對於實踐之私的瞭解的生活。其忽略了整全性要求之實踐反思論證的「互動與公共之性質」，亦漠視正義是社群共同產物的性格。Postema強調此種「新教徒主義」實不限於其法律理論，它是內含於Dworkin所理解之「解釋態度」⁶³。

然而，值得注意的是，上文有關Dworkin之解釋理論忽略法律解釋之實踐論證具對話論證之公共溝通性格的批判，是否誤解了Dworkin之真意呢？晚近Dworkin在回答Postema之批判時，坦然同意Postema之觀點；他再一次肯認整全性之追求本質上是共同的事業，承認整全性要求之實踐論證具互動與公共的性質，並強調整全性要求與對政治道德存在歧見的人們（包括官員與一般公民）一起共同追求探索共同之（廣義的）正義願景，共同一起對法律進行論理思索⁶⁴。的確，Dworkin早期即曾指出法律論證之目的係透過公民以及當事人對立的過程，以經由實驗而發展及測試法律⁶⁵。在描

61 *Id.* at 301.

62 DWORKIN, *supra* note 17, at 413.

63 Gerald J. Postema, "Protestant" Interpretation and Social Practices, 6 LAW & PHIL. 283, 296-97, 301 (1987).

64 Ronald Dworkin, *Replies to Critics*, in DWORKIN AND HIS CRITICS: WITH REPLIES BY DWORKIN 339, 386 (Justine Burley ed., 2004).

65 DWORKIN, *supra* note 13, at 216-17.

述以整全性為核心之政治時，他亦指出它乃是「社群應採那些原則作為體系之論辯的場域」⁶⁶。Dworkin後來在證立司法違憲審查正當性的同時，更指出美國式司法審查制度的優點之一即是藉由最高法院對於憲法議題之裁判提升了公共討論的品質⁶⁷。凡此似乎可看出Dworkin確實並未漠視法律論證過程之互動與公共的性質；亦即他並未忽略司法裁判之程序主義面向。然而，不可否認的是，他所提出之整全法的法律解釋理論，解釋者道德判斷的形成確實是獨白式的，其強調的只是解釋者之不同道德判斷應經自我反思的檢視以達於均衡，只是解釋者所賦予之目的、價值或原則與被解釋之實踐間的互動而已。其在理論上不曾有系統地探討解釋者間之論證互動對於解釋者道德判斷之形成有何助益，更不曾對於此論證互動之溝通程序必須預設之條件做過任何討論。從而，就Dworkin之觀點看起來，官員與一般公民固然係「共同一起」追求探索共同之正義願景，「共同一起」進行對法律之論理思索，但每個人似乎仍只是依循整全性原則各自建構論證形成一己之判斷。Dworkin所承認之實踐論證具互動與公共性質，似乎變成只限於將各自經由自我反思檢證形成之判斷提出於彼此，從而只是各自言爾志罷了。

更深入而言，之所以如此，與Dworkin僅從邏輯推理之意義來理解論證（即理由）之力量，而忽略下文Habermas所稱論證具語用學面向密切相關。亦即與Habermas不同，Dworkin忽略了一項規範性聲稱之理性基礎，係在於提出者能夠保證在必要時提供經得起聽者批判檢驗之令人信服的理由；反之，他堅持的是規範性聲稱應經得起自我反思之檢證，至於提出聲稱者能否提供令聽者信服之論證與該聲稱之理性（正確性）間（或者說不同意見者相互對話論辯與正確答案之獲致可能性間）具有如何之意義、存在如何之關係，

⁶⁶ DWORKIN, *supra* note 17, at 211.

⁶⁷ DWORKIN, *supra* note 12, at 345.

Dworkin並不曾在理論上有任何系統性的闡釋⁶⁸。的確，在論及法律意見之客觀性時，Dworkin強調的是吾人「僅應對自我盡力地說明一己之信念，雖然也應隨時準備放棄無法通過反思檢視的那些信念」。儘管他也同時指出「然後儘可能善意地對與吾人存在歧見之他人提出此一論證。而當沒有更適當的論證時，即終止再行論證」⁶⁹。但卻未提及論證提出後進一步互動溝通、對話論辯之必要性；面對歧見，仍僅須提出經過自我反思檢視的理由，並未強調必

68 審查人之一指出 Dworkin 在 JUSTICE IN ROBES 中明白表示 fit 與 justification 分別對應了兩種政治道德：即程序公平與實質正義。惟在相關文脈中，Dworkin 並未對程序公平作為 fit 此一面向之中樞有進一步的闡釋。See DWORKIN, *supra* note 49, at 171。不過，該審查人似乎隱含地對 Dworkin 此一論點作了闡釋。他指出在 Dworkin 看來，之所以要以既存的法律實踐當作詮釋的素材，係因為國會之立法決定必須是透過公平的民主程序而作出，基於民主與程序公平原則，透過民主普選產生之國會所制定的規範，因此是詮釋合法性時所必須符合的對象之一。假設這種對 fit 指涉程序公平性此一政治道德的詮釋是 Dworkin 的本意，則在程序與司法解釋之獲致正確答案間亦未建立連結；畢竟詮釋之對象是否是踐行公平程序的產物，與詮釋能否獲致正確答案並無相關。

此外，另一位審查人提及 Jeremy Waldron 對於 Dworkin 理論中隱含之程序面向的重建。惟 Waldron 該文主要目的，係經由對 Dworkin 理論之闡釋，發現其法治概念中蘊含「非常實質」之程序要素，以貶抑、甚至除去 Dworkin 理論中客觀主義要素——正確答案理論。Waldron 認為 Dworkin 強調的不是真的能夠獲致正確答案，反而是論證與挑戰的途徑必須保持開放。尤其是對於困難問題之答案必須堅持不斷地論證，即使在終局裁判作成之後。See Jeremy Waldron, *The Rule of Law as a Theater of Debate*, in DWORKIN AND HIS CRITICS: WITH REPLIES BY DWORKIN 319, 326-33 (Justine Burley ed., 2004)。不過，Dworkin 對於 Waldron 之回應，明白表示正確答案理論為其司法裁判理論之基石。See Dworkin, *supra* note 64, at 388。而且 Waldron 雖然指出 Dworkin 對於論證及持續論證之重視，並且認為此一程序主義蘊含有公民參與的要求。但 Waldron 並未顯示 Dworkin 之論證具本文所強調之對話論辯性格。此外，值得注意的是，國內學者莊世同表示 Dworkin 對 Waldron 之回應，係認為程序問題與實質問題均是有關政治道德的評價問題，且都有正確答案，至於兩者應當如何取捨或調和，則是兩個政治道德價值應當如何取捨或調和的詮釋問題。莊世同，合法性與整全性——對德沃金法治觀的審視與反思，收於：王鵬翔編，2008 法律思想與社會變遷，頁 58-60（2008 年）。此一論點自然有據。但就本文之立場，重點依然是有關程序途徑之深層內涵，程序在正確答案之獲致上究竟居於如何的地位，以及程序與個人之自我反思間之關係為何等問題，Dworkin 均不曾有理論上之系統性的闡釋，以致於程序在 Dworkin 之理論中的意義以及位置實不明確。

69 Dworkin, *supra* note 33, at 298.

須提出經得起歧見者批判檢驗之令人信服的理由；面對歧見並沒有義務重新省思檢視（並在必要時修正或放棄）原本經自我反思所得之判斷。同一文脈中，他甚至表示在決定吾人之判斷是否「真的」是正確時，抱持除了自我反思檢視以外，「尚有其他事可以有所作為這個觀念，吾人無法給予其任何意義」⁷⁰。然則，言說者彼此之間的互動性質上即很難說不是只限於各自言爾志而已。Dworkin甚至認為即使對於有關社群之政治秩序的最佳解釋為何，法官彼此之間存有歧見，每一位法官仍必須依賴一己之判斷：「每一位法官仍由於其不顧歧見的存在，努力地獲致一己之意見，而依然是肯認且增強了吾人社群之原則性的性格」⁷¹。據此，遵循整全性原則而進行法律理論的建構，遇到歧見之際，Dworkin強調的是「不顧歧見的存在」，致力於一己之自我反思，依然能夠實現社群之整全性的理想。然則，Dworkin強調整全性要求人們共同一起對法律進行論理思索，其意義除了各自言爾志以外，所剩為何？論者或謂Dworkin堅持單一正確答案之規制性理想的同時，另一方面又指出對於困難法律問題善意地追求正確答案之努力實際上經常仍會產生錯誤的答案，經常仍會出現歧見，因此他強調（包含公民在內）應該持續不斷的對於困難問題之答案進行論證⁷²。然而，Dworkin卻未對持續不斷論證與單一正確答案此一規制性理想間之關係有所闡論，二者間之關係依然不明。其實從Habermas程序主義觀點，二者存在重要之密切關係，而此一關係之解明，必須掌握論證之語用學面向以及司法法律論辯過程之語用學條件才有可能。此外，在單一正確裁判之聲稱的絕對性與實際裁判之錯誤可能性間所存在之間隙，亦有必要對此持續不斷之司法法律論辯過程的語用學條件進行探討釐清，才能封閉。

⁷⁰ *Id.*

⁷¹ DWORKIN, *supra* note 17, at 264.

⁷² Dworkin, *supra* note 64, at 388; DWORKIN, *supra* note 13, at 212-13. *See also* Waldron, *supra* note 68, at 326-32.

參、Habermas之司法法律論辯理論

Habermas司法法律論辯理論的提出係為了解決司法裁判領域中法安定性與正義（正確性）二項要求間之緊張關係，就此而言，Habermas與Dworkin之理論關懷並無二致。不過，相對於Dworkin之理論聚焦於法官獨白式地理論建構之理想上的要求，Habermas之司法法律論辯理論則強調裁判時法律理論形成之合作程序的理想上要求。Habermas之程序主義的理論取向使得其對於法安定性與正義（正確性）二概念之意義、從而亦使得調和二者之方式均作程序主義之重新的理解。

值得注意的是，Habermas之司法法律論辯理論堅持嚴格之權力分立，亦即他區分證立論辯與適用論辯，認為法官之裁判活動所涉及者僅限於後者。Habermas此一理論主張受到不少學者之批判。本文亦持反對立場。惟Habermas在討論法律實質化所造成之衝擊與因應之道時，卻又修正傾向於權力分立之相對化，強調面對法律實質化所帶來法律高度不確定性之普遍現象，司法之適用論辯必須為取自證立論辯之要素所補充。由於本文認為司法違憲審查經常涉及準立法活動，因此本文接受Habermas此一理論修正。從而，本文除了接受Habermas從程序主義之理論取向重新理解並調和法定性與裁判之正確性的論點，尚認為惟有司法違憲審查過程之法律論辯以某種方式納入證立論辯要素，方能確保司法違憲審查之程序理性，從而為憲法裁判實體內容之理性奠基。

一、對裁判正確性之程序主義的了解

就裁判之正確性而言，Habermas指出司法法律論辯理論不僅將司法裁判之正確性連結於論證的品質，亦將之與論證過程之結構相連結。亦即此一理論依賴強的程序理性概念，其將構成裁判正確性之性質不僅繫於建構論證之邏輯語意學面向，且繫於證立過程本身

之語用學面向⁷³。從而，司法裁判之正確性即與裁判過程是否滿足司法法律論辯過程之語用學預設密切相關。Habermas此一對裁判正確性作程序主義的理解乃是其論辯倫理學之延伸、運用。由於對論辯倫理學之要旨的掌握，對於理解Habermas之司法法律論辯理論具關鍵重要性，故先概述如下。

Habermas之論辯倫理學企圖在價值多元之現代，找到證立道德規範之普遍有效性（正確性）的基礎。Habermas將規範視為一規範性之有效性聲稱（*normative validity claim*）。他利用形式－語用學之分析，以顯示有效性聲稱對溝通參與者之意義，進而找出有效性聲稱之語行力（*illocutionary force*）。根據Habermas之分析，規範性之有效性聲稱之力量在於其聲稱某特定規範值得相互承認。因此在提出這樣一項聲稱時，即是將其聲稱公開供他人批判。並同時認其所聲稱是經得起這些評價、批判的。亦即有效性聲稱具認知的性格，它是可以被檢視的；有效性聲稱與理由及理據具內在連結，它同時是可受批判且可被賦予以理據，便是在此意義上，有效性聲稱是理性的。從而，言說者之所以能夠理性地促使聽者接受其言說行為之提議，即是因為此聲稱對於聽者而言，接受它是有好的理由的。當然這並非意味言說者必須列出這些理由，而是指言說者能夠保證在必要時提供經得起聽者批判之令人信服的理由。據上可知，Habermas係從規範性之有效性聲稱潛在上具令人信服之理由的角度，來闡釋規範所具備之互為主體的拘束力。由此即直接導出論辯理論。按當規範性之有效性聲稱其正確性為溝通之參與者所質疑時，即須進入實踐論辯脈絡。實踐論辯是以論證性討論為特色之溝通形式。過程中對於每個人提出之規範建議，作為隱含聲稱它具有正確性的言語行動本身，被要求提出足夠的理據，以為其規範命題中的有效性（正確性）聲稱作出經得起質疑者之批判檢驗的討論兌

73 HABERMAS, *supra* note 51, at 222-26.

現 (redemption)。從而能夠就具爭議之有效性聲稱的規範正確性，達成理性動機下所獲致之共識；亦即，經過理性討論來產生足以支持具爭議之規範性之有效性聲稱的理由，重新形成對其有效性之互為主體的承認。總之，Habermas視規範為規範性之有效性聲稱，並藉用形式－語用學分析言說之語行力的理性基礎，進而提出其論辯理論。

在這些基礎上，Habermas以論辯倫理原則 (principle of discourse ethics；下文簡稱(D)原則) 來表述其論辯倫理學之核心理念：「只有那些規範可以聲稱是有效的，亦即為所有可能受該規範影響之人，作為實踐論辯的參與者，均能同意的那些規範」。據此，規範的有效性被奠基於它在實踐論辯中對於所有參與者之「值得同意」之上；一項規範經由實踐論辯而獲致共識即確保該規範具普遍有效性或正當性。值得注意的是，(D)原則所指涉之實踐論辯，要求每位參與者僅以較佳論證為基礎，取向致力於共識之達成。而此一論辯之理性動機驅動性格又奠定在理想化之程序條件的預設上。Habermas依語用學重構吾人參與論辯時必須預設的論證規則，這些規則作為吾人參與論辯的必要預設具有普遍性的意義，這些規則至少包括：一、論辯過程之「公開性」(普遍性)規則；二、論辯參與者之「平等性」規則；三、論辯情境之「無壓迫性」規則。這些規則即形構了Habermas所謂之「理想言說情境」，乃是吾人在參與論辯時必然已經預設的，如此方可預期能夠獲致理性的共識。總之，就論辯倫理學而言，只有在實踐論辯中，遵守這些必須預設的語用學條件作為論辯進行的程序規範，溝通才是有意義的，而有意義的溝通最後保證了有關規範的歧見或利益衝突能透過論辯而取得共識，從而能夠確保規範具有普遍有效性。據上，Habermas藉由分析那些使實踐論辯的共識得以達成之語用學條件，而得到最基本的程序性規範，並據此作為證立規範之普遍有效性的理性基礎；換言之，就Habermas而言，理想化之程序條件，才是規

範正確性之決定性標準。從另一角度言之，相對於Dworkin建構解釋方法之獨白取向屬於一種個人主義取向之認識論（individualist epistemology），Habermas則強調規範性認知中之社會面向。他將認識的權威不再歸諸個別之認識主體，而係歸諸溝通社群。他指出認知基本上係溝通過程。規範性認知之真值取決於（為理想化程序條件所擔保之）溝通社群的真正共識；亦即在此，互為主體性（intersubjectivity）取代個別之認識主體⁷⁴。

Habermas之司法法律論辯理論即透過對司法裁判過程之重構分析，以揭示此一過程蘊含了其論辯倫理學之基本結構，從而彰顯裁判過程之程序理性，而為司法裁判之正確性奠基。其中之核心理念乃是司法裁判之正確性繫於裁判過程之滿足司法法律論辯過程預設的語用學條件。首先，Habermas指出司法裁判之「正確性（正當性；正義）」係指裁判為好的理由所支持從而具理性可接受性⁷⁵。而所謂好的理由係指在論證過程中，依論證規則，該理由對於具爭議性之有效性聲稱是否可接受的決定，是有助益的。進一步言之，

74 這部分對 Habermas 論辯倫理學之概述，see *Id.* at 228, 230; Jürgen Habermas, *Discourse Ethics: Notes on a Program of Philosophical Justification*, in *MORAL CONSCIOUSNESS AND COMMUNICATIVE ACTION* 43, 43-109 (Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen trans., MIT Press 1990) (1983)；李俊增，對哈伯馬斯論辯倫理學中普遍化原則之證立的檢證——兼論此項原則之有效性的限度，收於：蔡英文、張福建編，*現代性的政治反思*，頁 289-331（2007 年）；林遠澤，*意義理解與行動的規範性——試論對話倫理學的基本理念、形成與限度*，人文及社會科學集刊，15 卷 3 期，頁 401-429（2003 年）。

75 HABERMAS, *supra* note 51, at 226。Habermas 在討論司法法律論辯理論之脈絡中，對於正義、正確性與正當性這三個概念交互使用。由於如下述，Habermas 將正確性作程序主義地理解為「理性可接受性」，所以有時他又稱為正當性。此外，Habermas 固指出裁判之正確性係借自政治立法者通過之法規範所預設之有效性，而政治立法者所依賴者不限於道德理由，尚包括倫理或實用理由（詳下述），法官為裁判時即必須開啟這些正當化立法決定的理由。但不可忽略的是，Habermas 堅持善優先於便宜考量，正義又優先於善。從而利益妥協必須與特殊團體所承認之基本倫理價值並容；這些倫理價值又須與普遍有效之道德原則並容。HABERMAS, *supra*, at 166-67。據此，正確之裁判必須是合乎正義、合乎道德原則之裁判。

Habermas強調司法法律論辯中理由不僅具語意學性質；不能僅以邏輯推理之意義來理解理由之驅動力量。因此種意義下之理由僅能闡釋裁判之前提的內容，而無法對該前提作外部證立。反之，論證的觀念本質上具語用學的性質。論證乃是為兌現（redeem）或證實（validate）具爭議的規範性之有效性聲稱而進行之對話論辯中所提出之理由；論證（即理由）係理性地驅動論辯參與者接受該規範性之有效性聲稱是否為正確或有效之力量⁷⁶。換言之，理由與有效性聲稱具內在連結性。從而司法裁判所蘊含之規範性聲稱必須在所有利害關係人面前，以令人信服的理由證立。惟有在司法法律論辯中，能獲好的理由所支持而具理性地可接受性之規範性聲稱才具正確性或有效性。

Habermas承認正確裁判之存在，並認為正確性係指為好的理由所支持之理性可接受性，但他同時指出理由永遠不能以決定性證據之意義來理解其驅動力量⁷⁷。他強調法律論辯中無論何時永遠無法排除會有新資訊或更佳理由被提出的可能性，從而對話論辯過程是沒有終點的過程。固然在有利的條件下，對於具爭議之有效性聲稱可能形成非壓制性、具理性動機之共識，從而使得對話論辯出現一實際存在（*de facto*）之結論。但Habermas仍強調理由所構成之鏈子並無「自然的」終點，即使Hercules所建構之法律理論仍必須保持其暫時性，公開受持續的批判。此一持續不斷、恆具開放性之論證過程要求一項語用學預設，亦即質疑、批判本身必須以正確性之追求為名進行；單一正確裁判作為規制性的理想支配著論證過程，「此一過程因此獲得一方向性，而且至少終極而言是積累性、自我修正之學習過程，其中進步是可能的」⁷⁸。此項語用學之條件預設理想上並確保對話論辯過程，個案中所有相關之理由與資訊均能不

⁷⁶ *Id.* at 226, 228.

⁷⁷ *Id.* at 226.

⁷⁸ *Id.* at 227.

受壓制地提出，發展其驅動理性動機的力量。便是在此一意義下，Habermas指出司法法律論辯過程係一合作追求真理之論證過程，而此一論證過程理想上即封閉了單一正確裁判之聲稱的絕對性與實際裁判之錯誤可能性間的理性裂縫⁷⁹。

Habermas之司法法律論辯理論固取自其論辯倫理學。然而，Habermas同時亦強調不能視司法法律論辯為道德論辯之次類（subset），以論辯為基礎之裁判的正確性與有效之道德判斷並非完全相同。蓋「單一適當」之裁判判斷的正確性係借自政治立法機關通過之法規範所預設之有效性，而政治立法所依賴者不限於道德理由，尚包括其他如倫理或實用的理由。再者，裁判的正確性預設法規範之有效性，此一預設並非完全實現，所以法官必須面對對既存法律理性重構（或重構評估）的工作⁸⁰。從而Habermas認為司法裁判之正確性固要求必須合乎正義、合乎道德原則，但不應完全等同於道德判斷之有效性。

Habermas並進一步指出司法法律論辯不能視為道德論辯之次類，不僅係由於其自始即指涉民主制定之法規範，亦在於司法法律論辯本身即法律制度化為司法裁判之程序規則。然而，Habermas亦承認司法程序諸多程序上之要求對於論辯理論之實現構成了限制。換言之，對於論證程序之理想上的要求與對於規制之事實上需求所加諸的限制間存在著緊張，為了調和此一緊張，Habermas強調法律必須建立法律論辯為裁判程序之要素；裁判程序規則制度化司法裁判的進行，必須使得司法裁判之判斷及其證立可以視為論證過程的結果⁸¹。Habermas並對司法裁判過程作進一步之重構分析，以揭示此一過程某種意義上實現了論辯理論之理想上的要求。首先，針對

79 *Id.* at 227-28.

80 *Id.* at 231-32.

81 *Id.* at 234-35.

裁判程序中兩造當事人處於對立地位，以致法律論辯呈現對立的結構，Habermas指出此種結構有助於正確性（或正義）之發現。Habermas承認此種對立結構中，兩造當事人各自運用巧妙狡黠之論證提出策略，追求有利於己之裁判結果，就此而言，並非完全是合作追求真理之論辯結構。不過，當事人雙方擁有平等的機會來提出證據與論證，擁有自由地以其論證交互攻擊、防禦之空間，在這些程序制度設計下，Habermas強調這些採取策略性行為之機會同時也以確保相關資訊與理由儘可能被提出的方式予以組織起來，從而有助於司法法律論辯；從法官的角度，該論辯即法官獲致公正裁判之基礎⁸²。

再者，透過引進法官中立於兩造當事人而裁判的角色，也確保了裁判程序之公正性。進一步言之，上文曾指出Habermas在論辯理論學中引進(D)原則，係作為道德理論之核心原則，不過，在其法律論辯理論中則賦予此項原則更寬廣的解釋，他指出行為規範（包括道德與法律）之證立判準即為(D)原則，(D)原則係在解釋可以據以公正地證立行為規範之觀點；它闡述了實踐判斷中之公正的意義⁸³。他並進一步指出有關規範與價值決定之證立，(D)原則要求如下之論證實踐：即僅能從第一人稱複數互為主體地擴大之觀點，來判斷規範與價值是否獲致所有利害受影響之人理性動機下之共識。他強調此一觀點以既無強制壓迫且無扭曲之方式整合每一參與者之世界觀與自我了解。據此，Habermas認為法官在獲致其司法解釋時，有義務公正地整合所有相關當事人之觀點與社群無利害關係成員之觀點⁸⁴。從而，相對於Dworkin之法官的司法解釋係由融貫（符合性 v. 既存法律）與整全性（符合性 v. 最佳道德證立）標準所引

⁸² *Id.* at 235.

⁸³ *Id.* at 107-09.

⁸⁴ *Id.* at 228.

導，Habermas之法官⁸⁵

從融貫之規範體系觀點所形成之個案解釋，係依賴論辯之溝通形式，其社會學——本體論之構成允許參與者觀點與社群中無利害關係成員之觀點（由公正的法官代表）彼此相互轉變。……（從而解釋了）為什麼建構解釋中所運用之融貫的概念……指涉論證過程之語用學預設。

據此，Habermas之司法法律論辯理論要求公正性；要求法官考量裁判過程中所有相關之不同觀點，並以融貫且公平的方式使之彼此相互轉變或整合。亦即此一司法解釋活動並非狹隘地限於對法體系（原則、規則與判例）之解讀，而延伸包括動態地、轉變性地調和裁判過程中多重、不同的觀點⁸⁶。此外，Habermas並指出法官裁判必須公布之要求，意味著法官必須在當事人與公眾面前提出其裁判判斷的理由供檢視，從而亦迫使法官必須提供嚴謹的論證⁸⁷。換言之，法官之論證係被置於由法官、當事人、公眾間持續不斷論辯之巨視層次機制中，此一巨視層次的機制是法官在個案中提出好的理由之重要驅動力量。

總之，在Habermas看來，司法裁判程序某種意義上實現了其論辯倫理學之共識取向、公正性觀點之預設；裁判之正確性即繫於司法裁判過程滿足使得公正判斷可能之論辯溝通過程的語用學條件預設。從而，對於正確答案之理想上的要求並非如Dworkin之法律解釋理論所理解的那樣，係一種從擁有融貫性之理論上封閉的法律體系所作之實質的推衍。反之，正確答案是經由接近地符合程序性理

⁸⁵ *Id.* at 229.

⁸⁶ David Ingram, *The Sirens of Pragmatism versus the Priests of Proceduralism: Habermas and American Legal Realism*, in HABERMAS AND PRAGMATISM 83, 88-89 (Mitchell Aboulafia, Myra Bookman & Catherine Kemp eds., 2002); INGRAM, *supra* note 30, at 257-58.

⁸⁷ HABERMAS, *supra* note 51, at 236.

想之法律論辯過程，集體理性論證而產生，而且由於論證永遠不具結論性意義之驅動力量，而僅能驅動相互接受本質上具可誤性之規範性聲稱，所以論證最多只能說具程序性力量，符合正義之法秩序係來自永不止息之持續學習過程。

二、對法安定性之程序主義的了解

Habermas之程序主義地解讀正確性已如上述，同樣的，對於法安定性的理解Habermas亦採程序主義取向。Habermas固然指出法安定性原則要求裁判能夠在既存法秩序之架構內一致地形成，法律之制度史構成法官日常裁判之實踐的背景⁸⁸。但另一方面，如上述，與Dworkin類似，他強調對於既存法律之「理性重構」或「重構評估」⁸⁹。不僅如此，Habermas更指出古典的法安定性要求法官裁判具有條件程式之法律才可能確保之可預測性，並不可行；一個除了規則以外尚包含原則與政策之複雜法律體系必須放棄古典的法安定性。蓋原則（或政策）間之關係是浮動的，這些有效規範間之關係會隨著待適用之個案的相關特徵而改變。不可預測之情境會迫使解釋者在不同個案中對該套有效規範作不同之解釋⁹⁰。面對此法規範之不確定性，Habermas從程序主義之觀點對法安定性概念進行再解釋。他表示健全之程序係在不同層次確保法律安定性。程序權利僅確保訴訟程序當事人公平程序之聲稱，此一聲稱所確保的不是結果的確定，而是對於相關事實與法律問題之論辯地釐清。當事人可以確定的是產生司法裁判之程序中具關鍵決定性者，僅只具相關性的理由，而不是恣意的理由。他並指出倘視既存法律為理想上融貫的規範體系，則此一程序依賴之法安定性可以滿足致力於一己之整全性及取向於原則之社群的期待⁹¹。據此，Habermas從程序主義的觀

⁸⁸ *Id.* at 198.

⁸⁹ *Id.* at 219, 232.

⁹⁰ *Id.* at 219.

⁹¹ *Id.* at 220.

點再解釋法安定性之要求，扭轉了法安定性概念，法安定性不再指涉裁判結果之可預測性，而係指對於裁判理由之非恣意性的可期待性。後者並由以程序為核心之司法法律論辯理論所確保。依循司法法律論辯程序，資訊與論證可以自由、平等且充分地提出，以論辯地釐清案件相關問題，案件當事人因此可以期待裁判僅僅基於經此程序所過濾之相關理由而作成。

此外，Habermas並進一步指出個案中經司法法律論辯程序過濾之相關理由的範圍，能夠受到共享之法典範的實質限縮。倘公民與法官能夠對於法典範具有共識，則在法典範所決定之背景了解的範圍內，程序之結果對案件當事人即更增加一定的可預測性；對於法律之共享的「典範式前了解」表達了法律社群整體之自我了解，能夠降低法官對相競爭之規範進行排序時所面臨之複雜性，限制其間之不確定性，從而穩定化司法解釋，某種程度內有助於法安定性。進一步言之，Habermas強調法律之制定與適用會受到對於社會之特定意象或願景的引導。法典範即是由密切連結於特定社會意象之範例性的法院裁判實踐與解釋律則所構成之共享的背景了解⁹²。法典範將相競爭之規範予以排序，而且係依據法典範所內含之有關規範適用之特定情境的一般化描述而為排序。因此法典範構成了對於情境之評估與相關初步道德判斷所植基之背景脈絡⁹³。Habermas指出當代有二大法典範：自由主義與福利國法典範。前者，舉例而言，在契約法支持購者當心（*caveat emptor*）原則，與此相符應的是從自由經濟交易的觀點對情境為描述；後者在契約法則支持最低工資與利益原則，與此相符應的是從無法避免之社會成本（例如因景氣循環而導致經濟衰退）的觀點來描繪情境⁹⁴。

⁹² *Id.* at 388-92.

⁹³ *Id.* at 220-21.

⁹⁴ *Id.* at 221; *see also* Ingram, *supra* note 86, at 90.

不過，Habermas也注意到一個矛盾現象。如前所述，當法典範自我封閉而系統性地無視於環境激進的變化，排除對於原則與權利之不同解釋，即僵化成為意識型態。這一方面固然有助於法安定性的提升，另一方面，卻在更高的層次重新引進了不確定性。蓋一僵固的法典範下所作之關於個案的融貫解釋，仍然會與另一典範下針對相同個案所作同樣融貫的解釋相競爭，從而基本上仍然是不確定⁹⁵。換言之，由於不同典範的支持者在相同的法律領域內相競爭，法院在解決困難案件時，其個案判決結果將經常仍是不可預測。面對此一不確定性，Habermas仍訴諸其程序主義途徑謀求解決。他提出其所謂程序主義法典範。Habermas之程序主義法典範並不欲顛覆自由主義或福利國法典範，而只是要求二者捨棄一己所欲據有之獨占的指涉點地位。他指出無論自由主義或福利國法典範均是司法解釋之正當的基礎，因為它們均抱持法律社群係由自由且平等之公民所構成之觀念。但任何其中之一並不據有獨占的地位；蓋無論何者均未能充分地描述現代社會實在之複雜性，也均未能說明現代法律之規範性的正當性。自由主義或福利國法典範任何一者一旦據於獨占地位，必會損害一己所欲追求達成之願景⁹⁶。Habermas因此提出應居於支配地位的是程序主義典範。他強調自由主義與福利國法典範須在司法裁判程序中接受測試；法官在司法裁判程序中必須讓此二相競爭之典範的支持者進行對話論辯，從而對於其中一者之選擇與解釋均須公開於司法法律論辯中。法官經由調和此二典範，即可有較佳機會在諸選項中選擇最公平適用於個案之原則⁹⁷。

據上，Habermas從程序主義觀點重新理解下之法安定性，要求

⁹⁵ HABERMAS, *supra* note 51, at 221.

⁹⁶ *Id.* at 221, 392-427; 另參李俊增，程序主義與反思（身）法典範之爭：從哈伯馬斯對韋伯法理論之批判談起，歐美研究，42 卷 1 期，頁 106-115（2012 年）。

⁹⁷ HABERMAS, *supra* note 51, at 221-22; *see also* Ingram, *supra* note 86, at 90-91; 李俊增（註 96），頁 115-127。

的並非裁判實體結果之可預測性，而是司法裁判必須滿足司法法律論辯之程序條件的要求。換言之，法官必須忠實的乃是程序性質之法律的觀念；其安定性概念要求的是法官必須踐行審議論辯程序以形成其裁判判斷，從而可期待形成裁判之理由具相關性而非恣意的。這種程序主義之法安定性概念固然能在一定程度內降低法律之不確定性，但並不能完全確保裁判實體結果之可預測性或確定性。Habermas雖然期待藉由「典範性法律理解」之幫助，而實質地限縮經司法法律論辯程序過濾之相關理由的範圍，以進一步降低法律不確定性，但Habermas亦坦承由於法典範間之競爭，這並非完美的解決方案⁹⁸。不僅如此，Robert Alexy亦質疑指出像自由主義、社會主義或程序主義之法律理解的典範概念均高度抽象，因此在相當多情形並不足以決定一確定的裁判，它們最多僅能實體化原則間初步的優先順序⁹⁹。再者，如David Ingram所指出，面對後自由主義之資本主義的矛盾以及法體系的複雜性，Habermas之法安定性概念要求司法對話論辯以調和動態的、多樣的不同觀點與法典範，這也意味困難案件的解決必須承認可能無法在既存法律的基礎上被預測¹⁰⁰。總之，Habermas之程序主義的法安定性概念固然降低了法律不確定性，但也留下（甚至應該說也承認）一定程度之不確定性。

值得注意的是，上述Habermas程序主義觀點下之法安定性概念正能與其對裁判正確性之程序主義的了解相調和。一方面，如上述，Habermas指出正確性是指為「好的理由」所支持之理性可接受性，這與Habermas之法安定性概念強調對於裁判「理由之非恣意性」的可期待性，恰相符應；而且裁判之為「好的理由」所支持與具「理由之非恣意性」的可期待性均係經由司法審議論辯程序之踐

⁹⁸ HABERMAS, *supra* note 51, at 221.

⁹⁹ Robert Alexy, *Jürgen Habermas's Theory of Legal Discourse*, in HABERMAS ON LAW AND DEMOCRACY: CRITICAL EXCHANGES 226, 231 (Michel Rosenfeld & Andrew Arato eds., 1998).

¹⁰⁰ Ingram, *supra* note 86, at 89, 106-07.

行而獲得確保。另一方面，Habermas認為支持裁判正確性好的理由所構成的鏈子並無「自然的」終點，正義的追求是一恆具開放性之學習過程，個案裁判所建構之法律理論須保持其暫時性；亦即事實性（facticity）與有效性間一直存在緊張關係。如此之裁判正確性的概念，也正能與其承認一定程度之法律不確定性的法安定性概念相調和。據此，Habermas從程序主義觀點重新理解法安定性與正確性概念，藉由司法法律論辯（亦即程序理性之實踐）而調和並同時確保了二者。

無論如何，Habermas與Dworkin同樣承認法體系之複雜性，認法律除了規則以外，尚包含原則與政策，因此反對法律之解釋適用，主要是規則機械式的邏輯涵攝。然則，面對法體系之複雜性，司法裁判如何可能同時確保法安定性與正義（正確性）即是二人之裁判理論共同的關懷焦點。針對此，Dworkin之理論途徑強調經由個人獨白式的反思，以尋求達到既有法律實踐與最佳道德證立間之均衡。相對於此，Habermas則採程序主義的途徑，主張司法裁判活動，並非係法官個人之哲學反思，不應狹隘地僅就法體系進行解讀；反之，必須踐行審議對話論辯程序，個案中當事人可以平等、不受壓制地在法律論辯中提出各種不同的事實上、法律上理由以及對於法律相競爭之典範性的理解，法官則立於中立地位公正地轉變性調和這些不同的論證與觀點；藉此形式程序，即能同時確保法安定性與正確性。本文對於Dworkin之裁判理論的批判已如上述，從另一角度觀之，面對因社會快速發展所導致之未來高度不確定性且呈現多元主義之社會，以及法體系之複雜性（尤其是憲法中具高度抽象道德語言之基本權條款），程序主義地理解法安定性，承認一定程度之不確定性的不可避免，比起Dworkin堅持法律為整體融貫之理論上自我封閉的體系，顯得更為合理¹⁰¹；而程序主義地理解正

¹⁰¹ 抱類似肯定見解者，see *id.*; David Dyzenhaus, *The Legitimacy of Legality*, 46 U. TORONTO L.J. 129, 165, 176 (1996)。但對 Habermas 之程序主義的法安定性概念

確性，強調與另一合理的心靈相互溝通、進行論辯說服（與被說服）之程序條件，無疑亦較諸法官獨白模式，更有助於正確裁判之獲致。當然，Habermas之程序主義途徑的裁判理論也意味權利乃是社會建構的；亦即個案裁判中當事人應被、以及如何被相同或差別對待，當事人應該擁有什麼具體的權利，必須經由法官聽取利害關係當事人參與之審議對話論辯而為裁判決定。法官裁判公布供當事人與公眾檢視，並意味法官之裁判論證係被置於法官、當事人與公眾間持續不斷論辯之巨視層次機制中。從而，此一途徑無疑符應Habermas法哲學最核心的理念——私自主性與公自主性係同源的，彼此相互依賴¹⁰²。此外，亦符合前述Postema所論，法律所表達之正義原則作為社群之共同願景，必須經由公共的、共同的實踐反思論證來追求、達成。而不應是知識貴族－法官一個人獨白反思的結果而強加社群之上。

三、嚴格區分規範之證立與規範之適用及其修正

不過，值得注意的是，Habermas之司法法律論辯理論採取嚴格之權力分立的立場，嚴格區分規範之證立與規範之適用。對此，本文則採反對的立場。按Habermas借用Klaus Günther之理論，區分證立論辯與適用論辯。Habermas從其論辯理論的觀點重新詮釋權力分立原則，認為應依據溝通的形式及相關之論證模式來進行立法、司法與行政三種功能之區分¹⁰³。據此，Habermas區分規範之證立與規範之適用，前者專屬立法權，後者則屬司法權；這是因為規範之證立與規範之適用各自涉及不同之論證邏輯，而此一論證邏輯之差異

持批判立場者，see Alexy, *supra* note 99, at 231; HUGH BAXTER, HABERMAS: THE DISCOURSE THEORY OF LAW AND DEMOCRACY 111-13 (2011); Wesley Shih, *Reconstruction Blues: A Critique of Habermasian Adjudicatory Theory*, 36 SUFFOLK U. L. REV. 331, 380-82 (2003).

102 HABERMAS, *supra* note 51, at 126-27, 408；另參陳起行，論網路時代以論述為基礎的公共理性，東吳法律學報，19卷4期，頁6-21（2008年）。

103 HABERMAS, *supra* note 51, at 192.

又反映在證立論辯（discourses of justification）與適用論辯（discourses of application）各自之溝通形式上，這兩種溝通形式又必須以不同方式進行各自的法制化¹⁰⁴。

進一步言，證立論辯關係的是法規範之普遍有效性或正當性，亦即法規範之獲公正地證立。在此涉及Habermas依據其論辯理論，建構之程序主義法正當性理論。Habermas以程序主義的角度來證立規範之普遍有效性，就法規範而言，這係指制定法律之民主程序是法律唯一的正當性根源。這裡的民主程序則指在論辯原則（discourse principle）之引導下所建構之審議民主程序¹⁰⁵。據此，法規範之證立要求所有受該規範影響之人均能同意此項規範，其溝通形式之法制化因此要求這些受影響之人均被包括在內，均有平等且有效的機會，參與有關該規範之理性論辯；與適用論辯之法制化要求不同，其中只有參與者，沒有公正第三者之角色。

相對於證立論辯，適用論辯關係的不是法規範之普遍有效性或正當性，而只是將已獲公正證立之有效規範，公正地適用於個案；亦即這些有效規範只是有待適用之候選人，必須經由適用論辯，來決定其中哪一個規範在特定具體情境中是適當的，從而可以適用於該個案。適用論辯必須決定有關事實的描述何者對於解釋系爭個案之情境，是有意義而且是徹底的，一旦對於該情境之所有有意義的特徵已盡可能地瞭解，適用論辯即須從所有潛在上可能適當的規範中，決定哪一個有效規範在該情境中確實是適當的¹⁰⁶。上述規範之證立論辯中，要求所有受該規範影響之人均包括在內，且均是參與者，其中沒有公正第三者的角色；但適用論辯則與此不同，這類論辯之制度化要求的是當事人與法官間角色的分配，其中法官是法律

104 *Id.* at 172.

105 *Id.*

106 *Id.* at 172, 217-18.

社群之公正的代表，當事人則在其面前提出呈現個案所有具爭議的面向¹⁰⁷；尤其是提出各自對於具體情境之不同的解釋。總之，公正適用要求規則或原則之適用必須徹底且正確地掌握系爭個案情境之複雜的意義，而如上述，在形成有關這些情境之解釋時，其所依賴之論辯的溝通形式允許當事人之觀點與法官之觀點，彼此相互轉變¹⁰⁸。

Habermas狹隘地界定司法論辯限於適用論辯。同樣的，依Habermas之觀點，大法官職司違憲審查與一般之法律適用亦無不同，其涉及的仍僅是適用論辯。按Habermas對權利體系作程序主義的理解。憲法規定之權利雖具有實體內容，但這些權利乃是以法律形式實現公民之公自主性程序上所必要的，也是公民們想要自我建構成為由自由、平等之成員所構成的法律社群彼此應相互賦予的權利。從而權利體系業經程序性之證立¹⁰⁹。違憲審查所涉及的，因此並非權利體系之規範性內容的證立，而是蘊含於憲法與一般法律內、且業經證立之規範性內容之適用。Habermas指出職司違憲審查之大法官為了適用規範之目的，必須開啟包含於相關憲法或法律規定之規範性理由，只要其並非居於立法者之地位¹¹⁰：

憲法中可以取得之正當化的理由，從法之適用的觀點，預先被給予了憲法法院，……法院可以再開啟那組正當化立法決定的理由，以便為了獲致個案中融貫的判決而動用它們；但（法院）不可以以隱含立法的方式而使用這些理由。

¹⁰⁷ *Id.* at 172.

¹⁰⁸ *Id.* at 229.

¹⁰⁹ *Id.* at 123-24; Jürgen Habermas, *Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State*, in *THE INCLUSION OF THE OTHER: STUDIES IN POLITICAL THEORY* 203, 215 (Ciaran P. Cronin & Pablo De Greiff eds., 1998).

¹¹⁰ HABERMAS, *supra* note 51, at 262.

總之，Habermas嚴格區分規範證立與規範適用主張司法裁判（包括憲法裁判在內），僅涉及後者，僅要求適用論辯。惟進一步思考前述Habermas之裁判理論，可以發現他其實弔詭地承認法官之裁判活動會涉及某種形式之法之創造。上文Habermas在討論法律不確定問題時，他即承認原則（政策）間之浮動、競爭關係會導致法規範之具體意義與法體系隨著個案中法律之具體適用而變動。而面對此，他所提之程序主義的解決途徑仍承認一定的法律不確定性。再者，Habermas雖認司法裁判預設法律之（論辯）有效性，但亦強調此一預設無法完全實現，從而法與道德和諧之要求會導致對司法裁判之質疑。為了避免此一結果，法官無法避免對於被預設為有效之法律實踐進行理性再評估。理性再評估甚至可能得出部分之法律實踐史為錯誤之結果¹¹¹。針對大法官之解釋、適用憲法，Habermas更是坦承其中法律原則相競爭所致法律不確定的問題更為嚴重¹¹²。但在這些文脈中，他均未對狹隘地界定司法論辯限於適用論辯，有所鬆動。然而，如此一來，是否形成其法理論之內在矛盾，不能令人無疑。

的確，Habermas嚴格區分規範之證立與規範之適用，受到了諸多質疑，不少學者對於司法裁判過程中上述形式之法之創造活動，均認為有必要在證立論辯中予以證立。誠如Alexy對於Günther之理論所批判指出的，當規範具不確定性或發生規範衝突之際，在具體情境中何種規範為適當的決定會涉及規範內容之修正、改變，從而要求在證立論辯中予以證立。Alexy甚至認為規範之適用論辯要求考量適用具體情境的所有特徵，而且此一論辯會觸及新的歷史經驗，凡此均會使得既存規範體系更加精確、改變、被否定或重新創造，從而也需要在證立論辯中予以證立¹¹³。換言之，適用論辯與證

¹¹¹ *Id.* at 212-13.

¹¹² *Id.* at 243-44.

¹¹³ Robert Alexy, *Justification and Application of Norms*, 6 *RATIO JURIS* 157, 162-66,

立論辯無法嚴格區分，規範之適用關係的不僅是適當性，亦涉及規範之有效性。

此外，Ingrid Dwars在批判Günther之理論時，強調應區分法規範之法有效性與論辯有效性。倘一個規範係依據體系的標準制定，則該規範即具法有效性；不過，一個規範具論辯有效性，則指它就每個人之利益而言，為每個人互惠地接受。只有當立法符合理想之論辯情境，方能主張每一個具法有效性之法規範同時預設了論辯有效性。但由於這只是一種理想，論辯理論承認法規範之法有效性與論辯有效性可能分歧；亦即法規範可能僅具法有效性，而不具論辯有效性。既然如此，即不能以法規範預設論辯有效性而作為具體案件中司法法律論辯之基礎。蓋倘法規範預設論辯有效性，則在司法法律論辯中即無須從道德觀點予以批判；法官僅須中立地適用法規範，其裁判即是道德上正義的。但究諸實際，法規範之法有效性與論辯有效性既無必然、而只有可能的連結而已，法官在個案中仍有必要從更一般性之道德觀點證立其裁判之可接受性¹¹⁴。David Dyzenhaus亦從類似觀點指出，Habermas程序主義之法有效性理論中，事實性與有效性一直存在著緊張關係。但Habermas嚴格區分證立論辯與適用論辯，卻預設一旦證立工作完成，則實證法之內容已定，所剩只有法之適用，如此一來似乎即伴隨了事實性與有效性之

169-71 (1993). 有關 Günther 與 Alexy 間之辯論，涉及融貫概念以及 Günther 為解決融貫問題而引進之典範概念。針對 Alexy 此一論點，王鵬翔並作精緻地進一步分析，他指出個案中遇規範衝突情形會涉及規範之修正，此一規範修正可以視為獲致融貫的過程，其雖發生於具體情境中，但仍是一證立程序。蓋此一獲致融貫的過程最終取決於某種偏好關係，而此一偏好關係的決定必須予以證立；此一證立通常超越融貫標準，而奠基於偏好標準之上。Peng-Hsiang Wang, Coherence and Revision—Critical Remarks on the Günther-Alexy-Debate, in: Agulió (Hrsg.), Logic Argumentation and Interpretation, ARSP Beiheft vol. 110, 2007, S. 23 (23-30).

¹¹⁴ Ingrid Dwars, *Application Discourse and the Special Case-Thesis*, 5 *RATIO JURIS* 67, 72-74 (1992)；類似觀點，see CHRISTOPHER F. ZURN, *DELIBERATIVE DEMOCRACY AND THE INSTITUTIONS OF JUDICIAL REVIEW* 257 (2007).

緊張關係的消失。換言之，Habermas視裁判僅涉及適用論辯，而與證立論辯無涉，將形成其法律論辯理論之內在矛盾¹¹⁵。

就本文之主題司法違憲審查而言，基本權利條款之規範性內涵，其抽象、不確定之程度遠高於其他制定法；且這些權利條款表彰了道德原則，尤其憲法案件主要面對具體情境中原則競合情形而須進行原則之排序或調和等，憲法解釋因此會涉及道德判斷而無法免於重大之基礎性哲學爭議，從而憲法裁判較諸一般法律裁判實更有必要對爭議各方證立其所建立之法律（憲法）理論之理性可接受性。Hugh Baxter亦從類似觀點質疑批判嚴格界定司法論辯限於適用論辯此一論點在憲法裁判中成立之可能性。他指出美國最高法院在適用最一般性之憲法規範（如基本權條款中之「正當法律程序」或「平等保障」等）之際，常須建構未明白存在於憲法文本中之新的輔助性規則或標準，此一規則或標準不僅決定當下案件且支配了未來相關範疇之案件¹¹⁶。由於所建構之規則或標準在之前並不具任何權威性規範之地位，法院因此即必須對於該新規則或標準之建構、選擇提供證立，從而很難僅將之視為Habermas所謂之適用論辯。換言之，在適用像憲法基本權條款這種抽象原則之際，證立與適用功能並無法完全區分。即使同意Habermas有關證立與適用論辯之區分，在上述情形此二論辯亦同時存在於憲法裁判中¹¹⁷。據此，Habermas有關狹隘界定司法論辯限於適用論辯之理論在憲法裁判之

¹¹⁵ Dyzenhaus, *supra* note 101, at 165, 180.

¹¹⁶ BAXTER, *supra* note 101, at 121-23。此種由大法官建構未明白存在於憲法文本中之新的且支配未來案件之抽象性的輔助標準，在我國大法官解釋中經常可見。舉例而言，大法官針對刑法第 235 條散布販賣猥褻出版品罪是否違憲所作之司法院釋字第 617 號解釋中，即以抽象不確定之概念將猥褻出版物區分為二類：一類是「含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值之猥褻資訊或物品」；一類是「其他客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之猥褻資訊或物品」，而異其受言論自由保護的程度。

¹¹⁷ BAXTER, *supra* note 101, at 121-24. *See also* ZURN, *supra* note 114, at 257.

領域實更無立足之地。換言之，司法違憲審查涉及的不僅是法規範適用於具體情境之適當性問題，且很難避免涉及法規範之有效性問題，而須經由證立論辯予以證立。若思及司法違憲審查中之抽象法規審查的情形，則根本並非Habermas所謂規範之適用論辯所能解釋¹¹⁸。

然而，值得注意的是，Habermas在討論福利國家對權力分立帶來之衝擊時，面對法律實質化導致目標取向之法律計劃的出現，其中大量使用界定模糊之標準與概括性條款，Habermas似改弦易轍，而對司法論辯限於適用論辯之立論有所修正¹¹⁹：

就法律計畫需要法院進一步之具體化而言——因為儘管附有但書，立法與司法間之灰色地帶的決定傾向授此一權限予司法機關——司法適用論辯明顯地必須由來自證立論辯的要素所補充。

Habermas並直接指出「這些準立法之意見與意志形成的要素」，它們要求不同於嚴格意義之司法裁判的另一種正當化¹²⁰：

此一額外之正當化負擔可以部分地為法院之額外的義務滿足，即法院有義務在司法機關特有之擴大的、批判的論壇面前證立其意見。這要求法律公共領域之制度化，此一法律公共領域超越既存之專家文化，並充分敏感地使得重要的法院判決成為公共爭議焦點。

如果法律實質化造成目標取向、界定模糊之標準或概括性條款大量出現，形同賦予法官準立法權，以致司法法律論辯必須同時為

118 Habermas 認抽象法規審查屬於立法機關之功能，並主張應保留給立法機關，由其自我審查。See HABERMAS, *supra* note 51, at 242.

119 *Id.* at 439.

120 *Id.* at 440.

證立論辯之要素所補充。那更具開放性與不確定性之憲法規範必然使得憲法之解釋、適用與憲法之創造的界限愈趨於高度模糊，狹隘地界定司法論辯為適用論辯之立場因此必須放棄，立法之規範證立的問題當然即無法排除，司法違憲審查即必須以某種方式納入證立論辯要素，以為補充。否則，憲法裁判將因無法滿足其程序條件，而無法正當化；亦即將欠缺程序理性，從而損及憲法裁判實體結果之理性。

上論可以從前述Habermas法律哲學之核心理念－公與私自主性相互依賴，進一步申論。依此一理念，經程序主義證立之抽象的權利體系，其具體內容必須由公民自行審議來解釋、明確化，亦即必須經由審議的民主立法程序，方能正當地決定¹²¹。從而，由大法官職司解釋抽象之基本權條款，確定其具體內容（甚至可能推翻民主立法機關之決定），此一憲法裁判過程既涉及準立法活動，即必須以某種方式為規範證立（即審議民主）之溝通預設與條件所補充，

121 這也就是為什麼 Habermas 認為司法違憲審查應限於僅在確保「法律之民主起源的條件」，*see id.* at 265；亦即僅在維護審議民主之程序條件，以確保民主立法結果之正當性。乍看之下，Habermas 之論與 John Hart Ely 之「代表補強」的違憲審理理論，似乎類似，同樣主張司法違憲審查應限於維護民主秩序，實則二者有重大差異。蓋如前述，Habermas 視公與私自主性彼此相互依賴，因此憲政民主要求廣泛之權利體系作為其運作之必要條件。從而大法官實扮演了相當積極的角色；大法官可以介入審查之時機，不限於立法侵害了政治參與或適當代表之權利，尚包括侵害市民自由、文化團體成員資格之權利、用以確保公民實現法律所保障公、私自主性之平等機會的社會、經濟權利等。Habermas 即指出在關乎「民主程序之執行以及政治意見與意志形成之審議形式」的案件中，一個相當大膽之憲法裁判甚至是必要的。*See id.* at 279-80。據此，Habermas 雖從程序的角度來劃定違憲審查的範圍，但與一般從基本權維護以抗衡多數民主之論點所主張違憲審查的範圍，恐難分軒輊。更重要的是，其實不論違憲審查範圍之大小，大法官職司憲法裁判均必須進行規範之證立並無不同。即使是 Ely「代表補強」之理論，主張只有民主程序失靈，當民主之立法決定侵害人民參與民主程序之權利（如選舉權、政治性言論自由），或基於偏見而對某些「分散又隔絕的少數」予以歧視以致其無法或充分參與政治過程時，違憲審查才得介入。大法官之審查範圍因此被大幅縮小。惟案件中涉及之言論自由與平等原則同樣是高度不確定、抽象之政治道德原則，恐仍無法完全避免必須在證立論辯中予以證立之要求。

否則將侵害公民之公自主性。

值得注意的是，由於本文對於法安定性與裁判正確性概念係從程序主義作理解，此種法安定性概念下仍保留一定程度之不確定性，正確性概念且具開放性與暫時性性質，故而司法違憲審查納入證立論辯要素，恰與之相容。

不過，在上述引文中，Habermas僅粗略地提及法律公共領域之制度化，並未闡釋其具體內容，亦未進一步探討規範證立要素在司法法律論辯中其他可能實現的途徑。本文認為依Habermas之程序主義法律正當性理論，違憲審查既涉及準立法活動，則法律公共領域之制度化要求違憲審查程序與民主政治部門及公共領域必須存在某形式之連結，使前者為後二者影響，方足以正當化憲法裁判。本文下一節將對此深入解釋分析。並對現代民主憲政國家之違憲審查程序的制度與實踐進行重構，揭示其中即蘊含大法官與民主政治部門及公共領域間之對話論辯結構，藉此顯示司法違憲審查程序納入了證立論辯要素作為補充，某種意義上實現了論辯理論有關規範證立理想上的要求。此外，本文亦將重構分析指出職司司法違憲審查之司法機關普遍以人數頗高之大法官組成，以及大法官評議以自由、平等的方式進行等制度與實踐，其背後隱含大法官間之司法對話論辯過程接近Habermas之「理想言說情境」。據此，本文認為司法違憲審查涉及多重之對話論辯，並不限於法官－兩造當事人此一三角結構式的論辯。

肆、違憲審查過程蘊含之證立論辯要素與多重司法法律論辯之形構

如上述，本文一方面立足於Habermas之司法法律論辯理論，強調應從程序主義來重新理解並調和法安定性與正義，另一方面又主

張應接受Habermas之理論修正，強調司法違憲審查程序必須在適用論辯以外以某種方式納入證立論辯要素，為規範證立之溝通預設與條件所補充，方能說明其程序理性。本節將進一步解釋分析¹²²在符合司法獨立之憲法要求的同時，違憲審查程序必須納入證立論辯要素作為補充的深層意涵。此外，並將重構現代民主憲政國家之司法違憲審查程序的制度與實踐，以揭示違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間之連結形式，此一違憲審查程序蘊含之對話論辯，不限於法官－兩造當事人此一三角結構式的論辯，尚包括大法官與民主政治部門及公共領域間之對話論辯結構。這意味納入證立論辯要素作為補充本即為司法違憲審查程序之默示預設。此外，本節亦將重構職司憲法解釋機關之組成結構以及其他相關之制度與實踐，以

122 本節之解釋分析借用自 Habermas 之重構分析方法。重構分析方法係尋求揭示社會世界象徵地結構化之實在的深層結構，此一實在之深層結構僅能經由解釋而接近。其目標係在使意義表達的生產其背後隱含之實踐上具支配性的、前理論的 know-how 為之顯明；係在揭示其中之規則體系，而由於支配這些規則，行為主體方具能力生產意義表達。重構期望揭示的是其普遍有效性之 know-how。但另一方面，重構分析方法亦為一種經驗科學，重構所提出之假設奠基於經驗分析上，可以驗證或否證。惟與自然科學不同；與重構假設之形成與測試相關的資料主要係由行為主體之實際表現所提供。進而言之，重構分析係依循所謂「產婆助產 (maieutic)」程序（亦即經由適當例子與反例的選擇、對比與類似關係、轉譯與改寫等等），以揭示出行為主體相關之隱含的 know-how。See JÜRGEN HABERMAS, COMMUNICATION AND THE EVOLUTION OF SOCIETY 9-19 (1979); Jürgen Habermas, *Interpretive Social Science v. Hermeneuticism*, in SOCIAL SCIENCE AS MORAL INQUIRY 251, 258-61 (Norma Haan, Robert N. Bellah, Paul Rabinow & William M. Sullivan eds., 1983); THOMAS MCCARTHY, THE CRITICAL THEORY OF JÜRGEN HABERMAS 276-78 (1984); Jørgen Pedersen, *Habermas' Method: Rational Reconstruction*, 38 PHIL. SOC. SCI. 457, 457-85 (2008)。Habermas 指出其法律哲學即係在尋求一重構分析，以證明如果吾人參與民主與憲法之實踐，什麼是吾人始終默示預設的；亦即其法律哲學係對現代法律秩序蘊含之相關意涵進行重構，經由重構分析以闡釋現代民主憲政之法律體系之規範性的自我了解。See JÜRGEN HABERMAS, A BERLIN REPUBLIC: WRITINGS ON GERMANY 131-33 (1997)。其目的在藉此，從或多或少蘊含內在於現代法秩序的觀點（而非烏托邦之觀點），來掌握其尚未窮盡之理性潛力。同樣的，本節主要亦在對民主憲政國家司法違憲審查之制度及其實踐蘊含之溝通預設，進行重構，目的係希望藉此從多少內在於此一制度與實踐的觀點，來掌握蘊含於司法違憲審查過程內、尚待挖掘之程序理性潛力。

顯示其背後隱含大法官間互為主體性之對話論辯的溝通預設與條件，藉此闡明大法官裁判判斷之公正性的程序條件。據此，本文認為司法違憲審查蘊含有多重之對話論辯，並不限於大法官－兩造當事人之三角結構式的論辯。而為此多重法律論辯結構支配之司法違憲審查過程所具之程序理性，即確保了憲法裁判實體內容本身之理性的可能性。藉此本文希望從多少內在於司法違憲審查制度與實踐的觀點，來掌握蘊含於司法違憲審查過程內尚待挖掘之程序理性，而為實體憲法裁判之理性奠基。

一、違憲審查程序蘊含之證立論辯要素——大法官與民主政治部門及公共領域間對話論辯結構之揭示

要探討司法違憲審查程序之納入證立論辯要素，必須先知道Habermas之證立論辯在當代多元、複雜社會中如何實現。上文曾言及，Habermas以程序主義的角度來證立法規範之普遍有效性。這意味蘊含理性論辯結構之民主立法程序是法律唯一的正當性基礎。此一民主立法程序之特徵有二：一方面它是進行溝通審議之理性的意志與意見形成程序；另一方面，遵循此一程序確保了其立法結果獲致具理據共識的可能性。而後者又意味遵循此一民主立法程序之結果或多或少理性上是可接受的。亦即，法律之普遍有效性係為審議民主程序之正當性力量所確保。Habermas此一程序主義之法律與民主論辯理論在當代多元、複雜社會中之落實進一步涉及其非主體性溝通概念與雙軌之民主決策模式。此一模式同時聚焦在擴散於公共領域之非主體性、去中心化、非制度化之溝通，以及政治系統內制度化之審議與決策程序。換言之，Habermas論辯理論有關論辯之溝通預設與條件，其在自由民主國家立法程序之實現，即表現在代表政治意志之最終制度表現的正式政策決定機制必須與公共領域中意見與意志形成之非正式的論辯泉源相連結，使後者產生之溝通權力對於正式之政策決定具有真正的影響；以及一個自由、平等、未受扭曲、不受壓制之公共領域的存在。據此，法律本身必須經由公民

與其代表之更廣的論辯而正當化。立法程序必須與公共理性相連結，而後者又指涉公共領域中意見與意志形成之民主過程。藉由正式政治立法程序對未受扭曲、不受壓制且具活力之公共領域的充分開放，公共領域之溝通力量得以真正影響政治立法，從而確保民主程序產生為較佳論證所支持、具理據之立法結果的可能性。

就司法裁判而言，憲法保障法官獨立審判；法治原則要求法官獨立於政治與社會勢力之外，依據法律而為審判。惟法官獨立審判之制度，目的僅在維護自主、公正審判的空間，在不妨害自主、公正審判空間之條件（就司法法律論辯理論角度言之，這係由人數頗高之大法官的組成，配合大法官評議以自由、平等方式進行等制度與實踐，所形成接近「理想言說情境」之程序條件所確保，詳本節二、）下，並非謂司法違憲審查之制度與實踐不容許來自民主政治部門與公共領域之溝通力量，得以某種方式在一定之限度內影響大法官。更何況憲法雖要求法官依據法律而為審判，然依前述司法法律論辯理論觀之，司法解釋活動並不應狹隘地限於對法律體系之解讀，而應延伸包括動態地、轉變性地調和裁判過程中關於事實或法律之多重、不同的觀點。而司法違憲審查既涉及準立法活動，且不同於民主立法決定可以廢棄一般司法裁判，憲法裁判則可以廢棄民主立法決定。依上述程序主義之規範證立理論，違憲審查程序即必須與民主政治部門及公共領域有某種形式的連結；必須使得來自民主政治部門與公共領域有關憲法爭議之各種觀點能夠以某種方式影響大法官之解釋判斷。或者從另一角度言之，大法官在違憲審查過程中即有義務同時聽取、考量公共意見。違憲審查過程之法律論辯因此納入了規範證立之論辯要素作為補充，從而能夠正當化憲法裁判。

不過，司法獨立之憲法要求必然對於違憲審查程序與民主政治部門及公共領域之連結的可能形式，作了限制。質言之，司法獨立代表對大法官作為公正第三人之憲法要求。因此大法官即不得類似

代議士，成為反映相關憲法爭議之特定觀點的代表。反之，大法官作為第三人地位，有義務在聽取、考量案件當事人，以及來自民主政治部門與公共領域就相關憲法爭議之觀點後，公正地進行動態地、轉變性調和。進一步言之，這也意味司法違憲審查與民主立法性質上並不同。後者純粹僅涉及規範證立論辯，其中只有受規範影響之人參與有關該規範之理性論辯；只有參與者，沒有公正第三人之角色。但前者性質上主要仍是規範之解釋適用，涉及的主要仍是適用論辯，其仍要求法官作為公正第三者之角色；法官一兩造當事人之三角結構式之對話論辯仍然保留。雖然由於兼具準立法活動，違憲審查程序必須與民主立法部門及公共領域有某種形式的連結以受其影響；雖然除了法官一兩造當事人之三角結構式之對話論辯，尚必須包含納入違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間之對話論辯。但規範證立之論辯要素畢竟只居於補充地位，司法違憲審查所涉及之法律論辯，其中並非只有受規範影響之參與論辯者，而無公正第三者。不同的只是由於涉及規範之證立，法律論辯之參與者不應限於案件當事人，來自民主政治部門及公共領域對該憲法規範之相關爭議的對話論辯，法官並應有聽取、考量之義務。

無論如何，違憲審查既涉及準立法活動，其程序即必須與民主政治部門及公共領域有所連結，並受其影響。然而，此一論點並非只是理論上之理想；反之，它為違憲審查程序所默示預設。經由對現代民主憲政國家違憲審查程序之制度與實踐的重構，本節將揭示違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間之連結形式，指出違憲審查程序所蘊含大法官與民主政治部門及公共領域間之對話論辯結構。這項分析將顯示司法違憲審查程序以某種途徑納入了來自民主政治部門與公共領域之溝通力量，容許其在一定的限度內影響大法官。這意味憲法裁判程序以某種方式為規範證立之溝通預設與條件所補充，從而在某種意義上實現了論辯理論有關規範證立之理想上的要求。

的確，倘進一步對大法官產生方式、違憲審查過程以及憲法裁判公布方式等司法違憲審查相關制度與實踐進行重構，將顯示違憲審查程序包含大法官與民主政治部門及公共領域間，三重分析上可以區分，但關係密切、甚至相互重疊之對話論辯結構；違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間之連結形式的態樣，大致上即表現為此三重對話論辯之結構。茲就此三重對話論辯結構解釋分析如下，此一分析係奠基在相關之經驗分析（主要針對美國與我國¹²³）上。這些分析顯示實現證立論辯要素之途徑在不同國家已然以不同方式、不同程度地落實。

一、首先，就職司違憲審查之大法官的產生而言，各國普遍採不同於一般職司法律解釋、適用之法官的選任方式。按前者均經民主政治部門之提名、同意而任命。此一制度設計即意味了違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間之連結，其背後蘊含容許公共領域之溝通力量，可以透過民主政治部門決定大法官之選任的中介，而影響其憲法裁判（甚至包括法典範之變更或具範例式地位之重要判例的變更）之深意；其中並預設了大法官在某種限度內必須作為與民主政治部門及公共領域之溝通對話者的期待；他有義務聽取、考量來自民主政治部門及公共領域之聲音。尤其當某一憲法議題成為公共領域之討論、爭議焦點，則其所形成之溝通力量，更可能透過決定民主政治部門之選舉，而間接左右大法官之產生，影響憲法裁判。不過，此一制度途徑與民主政治可以經由民主選舉短期間一次性地、全盤性地且直接地變更立法或政策畢竟不同。由於大法官或為終身職，或具相當長之任期保障配合任期交錯制度，民主的力量並無法一次性地完全改變大法官組成之結構。加上審判獨立以及

123 本文認為美國與我國由於如下相對之特徵，而具一定程度之代表性：美國民主成熟而經驗豐富、公共領域強而有力、違憲審查實踐之歷史悠久、憲法發展為本國原創、採分散型之違憲審查制度；我國民主剛步入軌道而經驗有限、公共領域發展仍在起步、違憲審查實踐之歷史尚淺、憲法發展主要為繼受自他國、採獨占型之違憲審查制度。

判決先例拘束原則（依Habermas之理論，法官並非可以任意捨棄判決先例而不顧，而只是必須對之作理性重構評估）的要求，這些制度上之因素意味來自公共領域之意見，必須歷經相當長時間的淬鍊，經得起不同意見的質疑、批判，證明其具備足以修正或推翻既存之憲法裁判判斷的論證力量，其所形成之溝通力量方可能透過大法官更迭的中介而影響、修正或變更憲法裁判或其基本走向。這確保了憲法裁判不會如立法一般隨著民主短期的價值偏好或利益取向而隨波逐流，從而與法安定性之要求取得調和均衡。

由於大法官係由民主政治部門提名、同意而任命，從而公共領域所形成之溝通力量可以透過大法官之更迭的中介而影響、修正或變更憲法裁判或其走向。這在社會高度多元，公共領域強而有活力且違憲審查制度實踐已有悠久歷史之美國，具體實例並不少見。舉例而言，2000年，最高法院在*Stenberg v. Carhart*乙案中，宣告禁止不全墮胎（partial birth abortion）之Nebraska州法違憲，因該法未包含例外條款，允許母親為維護其健康必要時得為不全墮胎之程序權利¹²⁴。反墮胎團體隨即遊說國會通過類似上開州法之立法。2007年，由共和黨總統所任命之大法官居多多數下，在*Gonzales v. Carhart*乙案中，即支持上開國會立法。該案判決固未推翻憲法保障婦女基於其健康必要之墮胎程序權，卻認立法機關應擁有裁量權限來規制此一權利¹²⁵。美國如是，我國民主發展的成熟度、違憲審查制度實踐之歷史雖均遜於美國，但亦曾出現類似情形。司法院釋字第684號解釋之變更釋字第382號解釋即為適例。後者僅承認學生受學校「退學或類此之處分行為」得提起訴願及行政訴訟。前者則認大學「對學生所為行政處分或其他公權力措施，如侵害學生受教權或其他基本權利，即使非屬退學或類此之處分」，該權利受侵害之學生亦得提起行政訴訟。這兩號解釋分別作成於民國八十四年及

124 See *Stenberg v. Carhart*, 530 U.S. 914 (2000).

125 See *Gonzales v. Carhart*, 550 U.S. 124 (2007).

一〇〇年，其間歷經政黨輪替，大法官之組成結構完全不同，此一不同背後即反映了八〇年代初期與十餘年後之不同時空背景。前者戡亂時期終止未久，民主轉型正在進行，人民權利意識尚待啟蒙；後者民主轉型已然完成，人民權利意識日趨增強之公民社會亦已形成。美國與我國，不同國家實際實踐亦不盡相同，但透過民主政治部門而選任大法官之制度設計意味了違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間之連結，其背後顯示了司法違憲審查程序蘊含兩項預設：其一即大法官被期待在某種限度內必須成為與民主政治部門及公共領域之溝通對話者；他有義務聽取、考量來自民主政治部門及公共領域之聲音。另一則是一個強而有活力、未受扭曲壓制之公共領域。愈能接近滿足此一條件，則公共領域之溝通力量愈能透過民主政治部門之中介，而影響大法官之憲法裁判；亦即愈能滿足憲法裁判之證立論辯之程序條件。

二、然而，源自公共領域之溝通力量不僅可以透過大法官更迭之制度實踐的中介，而影響憲法裁判。在個案裁判期間，大法官通常即處於來自公共領域或民主政治部門的各種意見、聲音之中，這在系爭案件為眾所矚目之爭議焦點時尤然。按審判獨立僅是保障大法官有公正審判之空間，並非意味大法官因此即隔離孤絕於世。司法違憲審查既非在由「法律文本及邏輯論證」構成之密閉空間中進行，憲法裁判過程之法律論辯亦非僅以大法官一兩造當事人之三角結構的型態互動溝通。反之，司法違憲審查過程中，來自民主政治部門或公共領域之各種不同聲音透過非正式或正式的制度管道傳達給大法官，提供大法官多元不同但又豐富、充分的資訊與論證，構成了大法官作成公正、理性憲法裁判之重要基礎。

Michelman曾就此提出重要的理論建構。他認為當大法官在就基本且具爭議之政治道德哲學事項作出判斷決定時，只要他們能充分開放於有關這些事項之各種不同的觀點與論證，並與之對話，亦即大法官之判斷決定是自由且開放審議過程之結果，則此一決定即

具認識論上之可信賴性¹²⁶：

可信賴性是解釋者據以進行其工作之社會與制度條件中有意義的部分。對於可信賴性有重大幫助的一項條件，即是解釋者——道德解讀者——不斷地暴露於百花齊放之各式各樣有關各種解釋之正確性的意見中，這些意見係由社會中各色成員在聆聽其他成員出於其各自不同之生活史、當前處境與利益、需要所表達之意見後，自由、不受阻礙形成的。

大法官傾聽公共領域中各種不同的意見，並非意味大法官之裁判即應隨波逐流，以社會主流意見為依據。反之，其最重要意義在於一個多元社會中基於各種不同利益、價值觀所表達之法律論點均應受到充分的尊重、考量，因此，即使大法官的裁判與主流民意違背，也必須在審慎斟酌其意見以後，於裁判理由中以堅強的論辯理由回應。再者，大法官職司守護人權，一般而言，人權受立法不當侵害者，多屬弱勢、邊緣團體，從而大法官即需耐心聆聽、瞭解基於其價值觀與利益需要所表之法律論點，方能建構論證有效回應保障其權利。便是基於這些理由，Michelman認為與公共領域之互動有助於憲法裁判之可信賴性。如此一來，大法官一方面是對憲法權利條款作道德解讀之防衛並擴大個人自由（包括確保公共領域之平等參與機會與多元化）的自由主義者，另一方面又是願意傾聽並積極以論證回應社會各種不同利益、價值觀（尤其是沒有聲音的邊緣團體）的民主人士¹²⁷。從另一角度言之，這也意味每位公民均有機會參與此一發現政治道德問題之正確答案的論辯過程，並有所貢獻¹²⁸。

126 MICHELMAN, *supra* note 3, at 59.

127 *Id.* at 59-62.

128 *Id.* at 60.

然而，大法官憲法裁判之作成應開放於民主立法過程及公共領域，與之對話溝通，絕非只是學者之理論理想；反之，其為各國司法違憲審查之正式與非正式制度所默示預設。這些不盡相同之正式與非正式制度背後蘊含了大法官必須自視為與民主政治部門及公共領域間之溝通對話者。亦即大法官非自視應自閉於由「法律文本及邏輯論證」構成之密閉空間，亦非應自囿於法官－兩造當事人之三角結構的法律論辯中。反之，他們必須打開門窗讓一己暴露於各種聲音之中；他們自視職司憲法解釋者應兼聽、考量來自民主政治部門與公共領域分歧多元之意見與論證，與之對話論辯。

在美國，被Michelman視為是踐行Dworkin道德解讀途徑的代表人物——William Brennan大法官¹²⁹——的一段言論，甚至表現出大法官直觀地自我了解為與公共領域之溝通對話者。他認為大法官在作憲法裁判時，「不僅受判決先例及其所解釋之文本的拘束，而且無論基於任何具吸引力之政治與法學理論，亦應正視關注公共意見」¹³⁰。的確，美國學者即指出美國最高法院大法官會藉由觀察一般大眾對於下級法院同一憲法問題判決的反應，研究「法院之友陳述（*amicus curiae* briefs）」，注意大眾傳播媒體的分析，閱讀民眾的來信與電話紀錄，瞭解民意調查的報導，以及分析選舉結果的影響等管道，來研判社會大眾對於某一憲法問題之看法¹³¹。其中美國「法院之友」的制度更是充分表現大法官必須作為與公共領域之溝通對話者的深意。按此一制度允許與繫屬案件無直接利益關係之第三人向法院提出陳述，供法院參考。公共領域中各種公民團體如反墮胎協會、美國有色人種促進協會等因此能夠透過此一制度管道表達反映其意見，影響大法官¹³²。

129 *Id.* at 26-27.

130 William J. Brennan Jr., *Why Have a Bill of Rights?*, 9 O.J.L.S. 425, 435 (1989).

131 任冀平，美國最高法院司法審查權的行使：理論與實際，歐美研究，25 卷 3 期，頁 72（1995 年）。

132 LOUIS FISHER, CONSTITUTIONAL DIALOGUES: INTERPRETATION AS POLITICAL

從論辯理論觀之，「法院之友」此一制度無疑是大法官與公共領域間之重要連結。透過此一連結，違憲審查程序在制度上突破了適用論辯囿於法官——兩造當事人三角結構式之對話論辯的限制，而納入了大法官與公共領域之對話論辯結構；大法官有義務聽取、考量並回應公共領域中對相關憲法爭議之重要觀點，無疑有效地納入了規範證立之論辯要素。就我國而言，目前違憲審查制度並無類似美國「法院之友」的設計，因此大法官與公共領域間之連結缺漏了重要的一個環結。雖然如此，我國大法官審理解釋憲法案件，仍相當關注公共意見。舉例而言，大法官設置有剪報制度，收集範圍包括案件審理前、審理進行中以及解釋作成之後，所有報章雜誌期刊有關聲請案件的報導與評論，此舉實充分反映我大法官對公共意見之重視程度。此外，司法院大法官審理案件法第13條第1項亦規定，大法官解釋案件除聲請人外，並得依請求或逕行通知「關係人」說明，或為調查。遇重大爭議之案件，大法官為調查即經常召開說明會，邀請不同立場之學者、專家陳述意見，傾聽不同聲音。此一程序制度亦蘊含當基本權之解釋案件（例如「多元成家」法案一旦完成立法可能引發之聲請釋憲案件）在公共領域引發重大爭議之際，大法官邀請相關公民團體舉薦代表其立場之學者、專家與會陳述意見之可能性。

除了來自公共領域的聲音，由於大法官作為法律違憲或合憲之裁判時，係在推翻或肯認具民主正當性之立法及行政機關基於其憲法解釋所作之決定，因此亦會審慎考量民主立法或行政機關之意見，並在裁判理由中有效地論證回應，以證立大法官之裁判判斷，說服立法者。從論辯理論的觀點看，上開司法院大法官審理案件法第13條第1項規定大法官解釋案件應參考立法資料，並得依請求或逕行通知「有關機關」說明，正反映了此一論點。是大法官審理解

釋案件之際經常會召開說明會請政府機關派員到會說明。倘召開憲法法庭，無論是人民聲請案件或機關（或少數立法委員）聲請案件，均會邀請政府機關或相對立之機關作為他造當事人，出庭陳述意見。

在歐洲，以法國之抽象審查為例，雖法律未明文要求，憲法委員會仍會請求政府及國會多數意見，逐一回應國會反對派聲請案中之法律論證。同時並會搜集所有國會之辯論、委員會之報告以及立法過程中之其他文件¹³³。

在美國，副檢察總長（Solicitor General）代表聯邦政府，亦經常受邀以法院之友的身分參加訴訟，並因此被稱為最高法院「第九個半」成員¹³⁴，此外，雖然美國國會主要係依賴司法部維護其利益，但有時最高法院也會邀請參、眾兩院提出意見陳述，並充分參與言詞辯論。甚至國會個別議員也會受邀成為法院之友¹³⁵。

總之，上述正式與非正式制度之解釋分析顯示違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間有一定程度的連結。大法官憲法裁判之作成不應該、也不會自閉於密室中；反之，其暴露、開放於民主立法過程與公共領域。民主立法過程與公共領域之多元、豐沛的溝通流提供了大法官多樣之不同種類的資訊與論證，有助於相關之事實、法律問題以及所涉及之各種複雜的道德與倫理爭議論辯地呈現與釐清；憲法裁判面對此，有必要充分說理證立其道德判斷以作回應。或者就Habermas之理論角度而言，大法官必須傾聽瞭解並平等考量來自民主部門與公共領域之多元分歧的各種資訊與論證，並以公正的態度轉變性地調和這些不同的觀點與立場。當然，此一司法違憲審查之法律對話論辯過程蘊含了兩項預設。其一係大法官必須

133 SWEET, *supra* note 8, at 142-43.

134 FISHER, *supra* note 132, at 25-26.

135 *Id.* at 30-36.

自視為與民主政治部門及公共領域間之溝通對話者，從而自我開放於民主政治部門及公共領域，並考量、回應來自其中之各種不同聲音。另一則是一個充滿活力、未受扭曲之公共領域的存在。它容許各種價值觀點、不同利益立場均能自由且不受壓制地表達，包括社會中最邊陲、最弱勢的聲音。愈接近滿足這些預設，將愈能驅動大法官與民主政治部門及公共領域之司法對話論辯；亦即，憲法裁判證立論辯之程序條件愈能實現，從而使得理性之裁判結果更趨近於可能。

三、上文曾指出依據論辯理論，論證具語用學性格，論證（理由）與有效性聲稱具內在連結性。論證是理性地驅動論辯參與者接受特定規範性之有效性聲稱是否為正確或有效之力量。司法裁判作為一規範性之有效性聲稱，潛在上具有令人信服之理由；在面對質疑時必須且能夠透過對話論辯來予以兌現或證實。這闡釋了司法裁判具備互為主體的拘束力，從而具備正當性或有效性之條件。進一步言之，這也表示論證永遠不具結論性意義之驅動力量，而僅能驅動相互接受本質上具可誤性之規範性聲稱，從而司法法律對話論辯必須持續進行，不應在非理性動機下中斷終止。

就司法違憲審查而言，不同意見書及協同意見書的制度設計本身即意味憲法裁判具可錯誤性。再者，憲法裁判必須隨同協同意見書及不同意見書一併公布，即蘊含其可受公評之意；而接受公評又蘊含意味公評能影響未來之憲法裁判。就論辯理論而言，這並意味大法官必須了解論證具有語用學性格，面對批判有義務論證兌現以為回應。否則，裁判承認其可錯誤性並須公布接受公評之意義安在？批判但須絕對服從，然則批判之意義為何¹³⁶？換言之，此一制度實踐背後實藉由來自大法官內部以及民主政治部門、公共領域之

¹³⁶ 就一般之法院裁判而言，其公布引發公共領域之批判，可能匯集溝通力量，經由民主立法部門制定或修改法律而廢棄法院之裁判。

不同觀點、意見的挑戰、批判，以持續司法法律論辯，避免其恣意地在非理性動機下中斷終止的深意。據此，憲法裁判固具有確定終局效力，但這僅是基於憲法爭議最終必須有一權威性機關做出終局決定以定紛止爭之功能性的考量，絕非意味至此司法違憲審查之對話論辯即應告終止。當憲法裁判受到質疑，遭遇來自政治部門或公共領域之挑戰，面對新的資訊或論證（理由），大法官即有義務在日後相關案件中論證兌現以為回應；亦即有義務反思其過去之論證，並強化或修正、變更其論證以回應這些質疑、挑戰，甚至根本改變其原本之裁判判斷。此一大法官與民主政治部門、公共領域持續之司法法律論辯，提供了憲法裁判，至少終極而言，係在理性動機下被接受的程序條件；或者從另一角度言之，提供了調和法安定性與正義之緊張關係，使之趨於均衡之程序條件。

進一步言之，大法官作成之憲法裁判，如果具重要性毋寧將引起廣泛的注意，從而暴露於民主之互動批判中。這些批判不僅來自正式之民主政治機關，公共領域亦可能出現為抗爭憲法裁判之社會、政治動員。這些因為憲法裁判之論證而激發之批判討論，可能提供新的、甚至更佳的資訊與論證（理由），從而大法官必須重新審視思考其裁判，在下一次的相關案件中，或者更加精緻化其論證以為其過去之裁判辯護，或者擴大、限制、修正或變更其論證、判斷。此外，公共領域之政治、社會運動可能透過憲法訴訟之再行提出，挑戰原憲法裁判，亦可能凝聚成新一波的立法動力，針對被大法官宣告為違憲的法律，重新審議，制定類似規範內容的法律。此時再行訴訟者或立法者將不能僅以其特定倫理價值觀或利益偏好作為持論依據；反之，必須就原則事項提出憲法論證來證立其論證判斷，此項論證尤其必須回應憲法裁判之論據，否則法院即無義務重新審查，反思其原本之論證判斷。同樣的，法院面對社會運動推動產生之再行訴訟或具民主正當性之立法者重新通過的立法，也應抱持更為戒慎恐懼的態度，不得逕以違反既有憲法裁判而宣告其違

憲，而必須重新審思檢視其原來的論證與判斷，倘法院仍欲維持其違憲的立場，則應回應再行訴訟者或立法者所提之論據，補強其原來的論證，以說服之。另一方面，在此憲法對話過程中，該項訴訟案件將可能成為全國矚目的焦點，而引發公共領域熱烈的討論，包括媒體之報導與評論、法律社群之專業探討、社會動員支持或反對，甚至市井小民茶餘飯後間的閒談，由於原憲法裁判係法院基於憲法原則而作之裁判判斷，這些討論的焦點將被引導集中在原則事項上。當然公共領域熱烈且成熟之思辯、討論，也會反過來督促立法部門與司法部門，迫使其更審慎的反思其論證，提出更令人信服的理論，面對成熟思辯的公民，證立其立場。憲法裁判處於此一與民主立法部門及公共領域持續性憲法對話之溝通過程中，將不斷被重新審慎檢視、精緻化其憲法論證，甚至徹底改變其原本之論證判斷¹³⁷。

上述大法官與民主政治部門、公共領域持續互動之司法法律論辯的論點並為各國司法違憲審查之制度或實踐以不同方式、不同程度地被落實。這當中最為人熟知的即是美國。在美國，被最高法院判決宣告為違憲的法律，來自公共領域的不同意見可能遊說、壓迫國會制定內容類似的法律，最後甚至導致最高法院變更或修正其原本之裁判判斷。美國新政期間，民主政治部門不斷地重新制定內容類似之法律，挑戰最高法院之判決立場，終致最高法院改變其對於美國憲法之典範性的了解，最為人所樂道。上文所述，反墮胎團體遊說國會通過內容類似被最高法院宣告為違憲之法律，最後並使得最高法院在 *Gonzales v. Carhart* 乙案中部分修正了之前 *Stenberg v. Carhart* 案之立場，則為近日之適例。

137 大法官湯德宗對此則稱之為「權力分立動態平衡理論」。參湯德宗，立法裁量之司法違憲審查的憲法依據——違憲審查正當性理論初探，收於：權力分立新論，頁 36-39（2000 年）。

惟從某種角度觀之，我國卻有與上面論述相違之反例。按司法院釋字第185號解釋指出大法官解釋「有拘束全國各機關及人民之效力」。司法院釋字第405號解釋並進一步闡明司法院釋字第185號解釋之意旨，強調大法官之憲法解釋「不問其係闡明憲法之真意、解決適用憲法之爭議、抑或審查法律是否違憲，均有拘束全國各機關及人民之效力」；另一方面對於立法院違反司法院釋字第278號解釋意旨，重新制定與被宣告違憲之法律內容相同之法律，亦據此宣告該新法違憲立即失效。解釋中並明確指出：「立法院行使立法權時，雖有相當廣泛之自由形成空間，但不得逾越憲法規定及司法院所為之憲法解釋」¹³⁸。

不過，值得注意的是，司法院釋字第405號解釋之解釋理由書雖認立法院行使立法權不得逾越司法院所為之解釋，但它並非單純僅以此項理由宣告立法院重新修正之法條違憲失效。在該號之解釋理由書中，一方面固重申司法院釋字第278號解釋之意旨，認為新修正條文之規定將使在教育人員任用條例施行前已遴用之各類學校現任職員，取得與考試及格者相同之任用資格，牴觸憲法考試用人之意旨；但不僅如此，它並進一步指出此項條文亦違反憲法第7條

¹³⁸ 在德國，被聯邦憲法法院宣告無效的法律，國會可否重新制定內容相同的法律，聯邦憲法法院第一庭與第二庭見解歧異。以第一庭之見解而言，1987年第一庭認為該院的判決僅有法律效力，但立法者只受憲法秩序的拘束，其基於民主正當性，必要時自得再制定與被宣告為違憲之法律內容相同之法律。1997年一則有關規範特殊休假法律的裁判中重申第一庭的見解，不過，又特別強調：「聯邦憲法法院確認原法律違憲所持之理由，不能被忽略。是以，（違憲）規範之重新制定必須具備特殊理由，此種理由尤其是過去作為憲法上判斷之基準事實及法律關係，或是其基礎之觀點，發生重大改變，若缺乏上述理由，聯邦憲法法院即無義務重新討論業已決定之憲法問題」。從而依第一庭的見解，立法者在有「特殊理由」時，得重新制定與被宣告違憲之法律內容相同之法律。翁岳生，憲法之維護者——省思與期許（主題演說），收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務（六）（上冊），頁119-120（2009年）。據此，從司法法律論辯理論之角度觀之，其亦承認當國會之重行立法涉及基礎性之新的資訊或新的論證之提出，憲法法院即有義務重新審議其原本之憲法判斷。

平等原則，使未經考試及格者與取得公務人員任用資格者之法律地位幾乎相同，對於前開條例施行後以考試及格任用之人員有失公允。就此而言，實隱含大法官面對立法機關重新制定內容相同之規範，仍重新檢視其原來解釋之理由，進一步訴諸平等原則以補充精緻化其論證，回應立法者之挑戰。

果如本文所論，則司法院釋字第185、405號解釋即留下一種可能性：他日大法官於重新檢視其原解釋之後，若認立法者重新立法之理由較諸一己之論證更令人信服、更為堅強，可能即會變更其原本所持見解。司法院釋字第585號解釋變更司法院釋字第325號解釋之情形似乎可以作為此論之例證。在後者，大法官原認監察院為行使其彈劾、糾舉等權限，依憲法所具有之調查權，應專由監察院行使。立法院為行使憲法所賦予之權限，僅享有文件調閱權；換言之，依本號解釋，立法院之立法調查權並未包含對人之強制調查權。惟後來立法院為調查三一九槍擊案真相，立法通過三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例，卻賦予該委員會包括對人之強制調查在內的調查權。司法院釋字第585號解釋面對立法院此舉，並未引司法院釋字第185、405號解釋為據，以該條例逾越司法院釋字第325號解釋為由，而逕行宣告該條例違憲失效。反之，卻變更其在司法院釋字第325號解釋的立場及論證。相對於司法院釋字第325號解釋中，大法官強調立法院享有之文件調閱權係立基於與憲法賦予監察院之調查權的區隔上，本號解釋則認立法院為行使其憲法所賦予之立法權，「本其固有之權能」自得享有調查權；調查權乃立法院行使其立法權「所必要之輔助性權力」。大法官並指出立法調查權不限於文件調閱權，尚包括強制「要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見」之權力。

值得注意的是，無論司法院釋字第405號解釋所涉及教育人員任用條例之重新立法，或司法院釋字第585號解釋涉及之三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例之立法，二者之立法動力均來自公

共領域。前者是未經國家考試及格之學校現任職員動員對立法委員遊說的結果；後者之立法的背後動力，無疑是來自三一九槍擊事件後對行政機關以及其調查抱持深度懷疑之人民。凡此，某種意義上可以說係來自公共領域之意見推動了立法院之立法，挑戰大法官既有之解釋，從而驅使大法官重新審視其原本之解釋論證，以為回應。尤其是司法院釋字第585號解釋之作成，面對的是國會立法係基於對行政機關空前不信任之新的事實，因此也使得大法官變更其原本之論證與判斷。

我國與美國上述正式或非正式制度當然有不少差異，但無論何者背後均蘊含了兩項預設。其一係大法官了解其憲法裁判之論證具語用學之性質。面對來自公共領域及民主政治部門對其憲法裁判之挑戰，他們必須更精緻化或修正（甚至變更）其論證以為回應。另一則是一個未受扭曲、壓制且充滿活力之公共領域的存在。愈接近滿足這兩項預設條件，則愈能驅動大法官與民主政治部門及公共領域持續互動，進行司法法律論辯，從而確保了憲法裁判，至少終極而言，具理性之可接受性；亦調和了法安定性與正義間之緊張。

以上藉由對大法官產生方式、違憲審查過程及憲法裁判公布方式等司法違憲審查制度及實踐之重構，揭示了司法違憲審查程序中大法官與民主政治部門及公共領域間之連結形式，其態樣大致表現為三重密切相關（甚至相互重疊）的法律對話論辯，這意味納入證立論辯要素作為補充為司法違憲審查程序所默示預設，從而為兼具準立法性格之憲法裁判提供了理性之基礎。這三重司法法律對話論辯一個共同之核心的預設條件即是一個未受扭曲、壓制且具活力之公共領域。愈接近滿足此項條件，則來自公共領域之溝通力量愈強，也愈能驅動這三重法律對話論辯，而影響大法官之憲法裁判¹³⁹。此外，另一項重要之預設條件即是大法官必須了解其憲法裁

139 美國的歷史經驗顯示其人民長久以來持續透過各種方法——靜坐、抗議、政

判之論證具語用學性格，自視為與公共領域及民主政治部門之溝通對話者，從而有義務考量、回應來自其中之不同聲音。據此，整體而言，在某種意義上，有關憲法上政治道德問題之真理的探求，是由公民集體參與的過程。每位公民運用其公的自主性，表達基於其利益與價值所持之憲法法律論點，均對於此一探求過程有所貢獻；憲法裁判的形成不是由大法官片面獨白決定作成的，而是公民與大法官協力過程的成果。這一過程並且是一對話式論證之溝通過程，每位公民自由的表達基於其利益與價值觀所持之憲法法律論證，大法官則於其裁判中建構論證以為回應¹⁴⁰。

治運動、文化與社會說服、提起訴訟等，在各類涉及憲法權利之問題上（例如：1960 年代之種族問題、1970 年代之性別問題、當代之墮胎、同性戀與宗教等問題）進行奮戰，傳達其價值理念，試圖形塑憲法之意義內涵。學者指出這些實踐促使了法院與公眾間之持續的溝通。See Robert C. Post & Reva B. Siegel, *Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash*, 42 HARV. C.R.-C.L. L. REV. 373, 379-80 (2007)。有學者甚至強調美國法院有關憲法原理之有意義的改變通常來自政治、社會運動之長期的刺激所致。See Jack M. Balkin, *Framework Originalism and the Living Constitution*, 103 N.W. L. REV. 549, 593 (2009)。

我國公共領域之活力與美國固不能同日而語。惟近年來，亦日趨活絡，出現一些公民團體，如廢死聯盟或同性戀團體，挑戰大法官有關死刑合憲（司法院釋字第 476 號解釋）、婚姻制度為男女結合之一夫一妻制（司法院釋字第 552、554 號解釋）等相關解釋意旨。假以時日，這些社會運動或可收其成效，開花結果。

- 140 審查人之一指出本文雖然強調大法官與民主立法過程及公共領域之互動；大法官為了說服立法者接受其判斷，必須考量立法過程中與公共領域中之公共意見。但這些意見是否足以構成論證之良好理由，仍是由憲法法院的內部對話過程所決定。從而並無法保證憲法裁判必然滿足(D)原則之證立要求：「規範的有效性被奠基於它在實踐論辯中對於所有參與者之『值得同意』之上」。
- 關於此一質疑，會因違憲審查係屬具體法規審查或抽象法審查，而有不同的效度。就具體法規審查而言，違憲審查基本上仍係規範之適用，涉及的主要是適用論辯（例如：面對案件事實，相關憲法原則之優先排序哪一種為適當之決定）。只是由於其會涉及準立法活動，故必須為證立論辯之要素所補充。因此程序中除了參與者，仍需要作為公正第三者之法官，惟要求法官不僅有義務聽取、考量案件當事人之意見，更應擴及民主政治部門及公共領域之聲音，然後公正地進行轉變性地調和（詳見本節前言）。此一主要為適用論辯，並以證立論辯之要素作為補充之司法違憲審查過程，即不能以未能完全符合(D)原則之證立要求，而質疑其未滿足司法法律論辯之程序條件。
- 惟就抽象法規審查而言，此種違憲審查經常被質疑性質上根本即為立法活

不過，值得注意的是，上述證立論辯要素畢竟只是補充違憲審查過程，違憲審查本質上仍具司法性格，它要求大法官在其中扮演獨立而公正之角色。從前述Habermas之司法法律論辯理論而言，這意味大法官有義務公正地轉變性調和案件當事人與來自民主政治部門或公共領域之不同立場與觀點，並對之論證證立其裁判判斷。然而，不僅如此，基於大法官之本職即係保障基本權利、維護憲法原則，他並有義務促使司法違憲審查之相關憲法議題的法律對話論辯能夠置重點於原則事項，亦即側重政治道德問題。換言之，大法官作為憲法原則之守護者，其角色功能亦在確保作為訴訟爭點之憲法議題的法律對話論辯係原則取向的。

二、大法官合議所形成之對話論辯結構

Habermas之司法法律論辯理論，法官扮演了關鍵重要的角色，他有義務公正地轉變性調和案件當事人之不同觀點。其中並非由（接近地）符合理想程序條件之對話論辯，而係由孤獨的法官來確

動，而非司法活動，因其間並不涉及規範之適用。這也就是為什麼 Habermas 會主張抽象法規審查應保留給立法機關，由其自我審查，*see HABERMAS, supra* note 51, at 242。當然本文有關違憲審查程序納入規範證立要素之論述「部分緩解」了大法官進行抽象法規審查之正當性的疑慮。不過，如本文一再強調的，證立論辯要素在司法違憲審查程序中僅居於補充地位，所以也只能夠是「部分緩解」而已。按雖然違憲審查程序涉及大法官與民主立法過程及公共領域之對話論辯，憲法裁判之作成有義務考量公共意見，但畢竟仍是由大法官作最終之判斷決定，而不是奠基在對於所有參與實踐論辯者之值得同意的基礎上。因此抽象法規審查而作成之憲法裁判如何能夠保證滿足(D)原則之規範證立要求，確實如審查人之一所質疑的有其問題存在。

據上，我們也可以說具體法規審查較諸抽象法規審查更接近滿足論辯理論之程序條件的要求。惟從司法違憲審查史之宏觀的角度觀之，經由司法違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間持續不斷的對話論辯，來自民主政治部門及公共領域之溝通力量終究會促使大法官修正或推翻其認為不符正義之憲法裁判。這也符合 Habermas 及本文之觀點：視單一正確裁判為規制性理想，為此理想支配之司法裁判過程係一積累性、自我修正之學習過程。就此而言，憲法裁判的形成確實不是由大法官片面作成，而是公民與大法官持續對話論辯過程的成果；理性之司法裁判因此係由公民與大法官協力、持續追求實現之計劃。

保公正性，因此不免遭到學者之質疑¹⁴¹。在司法違憲審查中，依上論，大法官必須轉變性地整合者包括來自民主政治部門以及公共領域之不同觀點，大法官能否維持其公正性，質疑勢必更大。按之所以能夠期待法官來確保公正性，當然是由於其居於第三者之地位以及制度上保障法官之獨立性。但法官究非上帝，他只是人，他來自社會，往往持有一定之道德價值信念。然則，如何能期待大法官不致於偏聽，能夠平等考量他所聽取之各方不同觀點，並公正地調和、作出判斷？本節將藉由重構分析指出，就司法違憲審查而言，由於各國職司憲法裁判之機關，普遍均由複數大法官所組成，而且其人數頗高（美國聯邦最高法院由九位大法官組成；德國憲法法院分兩庭，每庭由八位大法官組成；我國大法官更高達十五位），此一組成結構配合大法官評議以自由、平等方式進行等相關之制度與實踐，蘊含意味大法官違憲審查過程接近於上述Habermas所謂之「理想言說情境」。本文認為此一接近地符合理想之程序條件即確保了大法官在聽取各方不同意見之後，能夠公正地進行轉變性的調和。茲進一步闡論如下：

（一）與政治機關代表民意，且須對民意負責不同，大法官係獨立審判。按各國有關大法官產生方式之制度規定（包括由行政機關提名經國會同意，以及被提名大法官須具備一定之資格條件）即意在降低大法官選任過程中政治、黨派因素恣意、不當的干擾影響。尤其重要的是，各國憲法均有法官獨立審判之規定（我國司法院釋字第601號解釋亦明示職司解釋憲法之大法官為憲法上法官，須以遵守憲法第80條有關法官獨立審判規定為其憲法上義務），並以身份保障制度（或規定大法官為終身職或採任期制。我國憲法並繼受德國法制，有任期交錯及不得連任之規定）來確保大法官之獨立地位，不用就其裁判結果，對任何人負責。此外，個別大法官若

¹⁴¹ Ingram, *supra* note 86, at 104.

與案件有任何利害關係，亦有迴避制度之適用，因此大法官與裁判結果並無任何直接的利害關係。大法官此項獨立審判之制度目的，係為保障裁判過程中大法官之參與討論，能避免取向於個人目標達成之策略性考量，而以憲法原則為據，致力於追求公正，發現真理或正確的答案。再者，比起代表民意之立法者須扮演多重角色，大法官之角色單純許多，限於基本權之保障與憲法原則之維護。大法官們彼此協力從事唯一的一項共同事業－保障及擴大每一個人之權利，這是司法違憲審查制度設置的目的，也是政治社群對大法官評判的標準，更是大法官對一己角色之自我了解（我國司法院釋字第601號解釋即指出：「大法官解釋憲法之目的，在於確保民主憲政國家憲法之最高法規範地位，就人民基本權利保障及自由民主憲政秩序等憲法基本價值之維護，作成有拘束力之司法判斷」）。

（二）立法機關中之成員通常須服從黨意，受黨鞭之指揮，因此成員間之地位並非全然平等；且各政黨之席次不同，黨派之政治勢力亦呈現強弱不平等之勢。與此相對的，職司憲法裁判之機關不僅由人數頗高之大法官所組成，大法官彼此間之地位且絕對平等，任何一位大法官對於案件之立場以及相關之論證與資訊，均有平等而充分的機會可以自由的提出；亦可以自由地對每一種立場及論證進行質疑。沒有任何來自溝通過程內部的壓迫。大法官對於憲法裁判之主文或理由執不同意見者均可以撰寫不同意見書或協同意見書，並隨同憲法裁判一併公布，此一制度設計就某個角度觀之，正蘊含憲法裁判案件審理過程中，容許不同意見平等地自由提出，從而具體體現大法官溝通、論辯過程滿足平等、自由、無壓迫性之程序條件。（我國司法院大法官審理案件法第2條規定大法官「合議」審理憲法解釋案件。再者，大法官分受聲請解釋案後，雖先由三位大法官組成之審查小組研擬作成審查報告，但依司法院大法官審理案件法施行細則第11條第3項規定，對於提報大法官全體審查會議之審查報告，每一位大法官均得自由提出意見。類此制度規定更明

白顯示大法官係以自由、平等方式進行評議)。此外，司法獨立亦確保了此一溝通過程之平等、自由的條件不會受到來自外部強制力的干擾。

(三) 如上文所論，司法違憲審查過程不僅包含大法官－兩造當事人間之三角結構式的對話論辯，尚涉及大法官與民主政治部門及公共領域間之對話論辯，這意味訴訟當事人以及民主政治部門、公共領域提供了大法官多元、豐富之不同資訊與論證，使得相關事實、法律問題以及涉及之各種複雜的道德、倫理等爭議得以論辯地呈現與釐清，從而成為大法官獲致公正裁判之基礎。

(四) 大法官審理案件之論辯、溝通過程僅能訴諸論證說理，提出較佳的論證或令人信服的理由作為其判斷之正當性的基礎，以說服其他大法官接受其立場。這一方面是因為大法官之正當性並非來自民意的支持，或代表任何社會、政治勢力，因此沒有任何大法官能夠以民意偏好的趨勢或所代表社、政勢力作為其判斷之正當依據，說服其他大法官。更不能恣意地訴諸其個人之道德信念或使用其他強制脅迫的方法，要求或迫使其他大法官接受其判斷。另一方面，大法官既不代表任何民意或社、政勢力，又不擁有任何軍、警武力，大法官亦僅能以論證說理來作為其憲法裁判之正當性基礎，說服政治機關與社會大眾接受其裁判。的確，憲法裁判要求必須撰寫大法官如何形成其判斷決定的理由，相關之協同意見書或不同意見並與之隨同公布。在實踐上，遇重大憲法爭議問題更可見大法官長篇累牘、不厭其詳之論證說理。凡此背後均蘊含不論來自憲政國家之期待，或基於大法官之自我了解，大法官憲法判斷唯一的正當性基礎即是以理服人。專注於論證說理的提出，並以較佳之論證作為審視其他大法官之判斷可否接受之唯一的判準，因此形成大法官內化之專業倫理。

(五) 大法官就案件之判斷及論證說理的提出，係為維護憲法

原則，以公正為依歸，真理或正確答案之發現為目標。至於所謂真理或正確答案，就司法法律論辯理論之角度而言，即係指大法官轉變性地調和不同觀點成為一公正之憲法判斷，且由於具備較佳的論證而贏得所有其他大法官，在無任何壓制強迫下，欣然接受者。因此，以真理發現為目標之大法官，即在尋求為較佳論證所支持之公正的憲法判斷，以贏得所有其他大法官之肯認。當然共識之達成只是一項預設或期待，它意指所有參與憲法裁判之大法官均自我導向於共識之目標，此一目標對他們而言原則上是可能的；亦即他們預設了錯誤的見解與論證被說服改變是可能的（至少就終極而言，是可能的），這項可能性確保了參與討論的意義，也確保了憲法裁判基於理性動機被接受的可能性。大法官評議（或合議審理）的制度背後即蘊含大法官憲法裁判案件之審理係取向於共識之溝通行為，蓋倘若經由論證說服而改變立場並不可能，則何以需要討論評議。

當然，可能的情形是現實上沒有任何一項法律理論能獲所有大法官接受，但迫於結案之壓力，必須作出決定，因此有（特別）多數決機制之設。不過，多數決的決定應視為只是代表仍將持續不斷之討論的暫時休止。多數決決定應視為暫時被迫中斷之論證過程中具理性動機但可能錯誤之結果，它是可以推翻的。少數同意以多數決方式作出裁判，但這是附有但書的，亦即他們保留有機會可以在將來以其論證贏取多數，修正先前的決定。協同意見書與不同意見書隨同憲法裁判一同公佈之制度，以及上一節所述大法官面對挑戰其憲法裁判之立法進一步論證回應等實踐，正蘊含了這些意見有機會在將來類似案件中說服多數，甚至全體大法官的意涵。再者，不同意見書隨同憲法裁判一起公布之制度，也使得多數意見必須就不同意見提出論證回應，以便供公共領域檢視、批判，從而亦可降低多數意見之恣意不合理程度。

以上所論有關司法違憲審查，大法官間互為主體性之對話式論證過程之溝通條件的重構，顯示其接近於上述Habermas所謂之「理

想言說情境」¹⁴²。此一理想之程序條件對大法官由於個人之道德信念可能造成之偏頗提供有意義的制衡，確保了大法官對於不同觀點進行轉變性調和之公正性的可能性。這些溝通條件隱含於司法違憲審查之相關制度與實踐的深層結構，對其之重構顯示憲法裁判之理性同時為大法官間對話式論證過程所蘊含之程序理性所確保。

本節首先解釋分析指出依論辯理論，規範證立論辯之理想上的條件要求違憲審查程序與民主政治部門及公共領域必須存在某形式的連結，使前者為後二者影響。本節並對司法違憲審查程序進行重構，揭示其除了法官－兩造當事人三角結構式之對話論辯，並蘊含大法官與民主政治部門及公共領域間之對話論辯結構，藉此顯示違憲審查程序納入了證立論辯要素作為補充。本文並經由對職司違憲審查之機關的組成以及其內部評議方式等制度，進行重構，指出大法官間互為主體之對話式論證過程接近「理想言說情境」，其形成另一重對話論辯結構。為此多重法律論辯結構所支配之違憲審查程序所蘊含的程序理性即確保了憲法裁判之實體內容更趨近於理性之可能性。藉此本文從多少內在於違憲審查制度及實踐的觀點，掌握了司法違憲審查過程尚待挖掘之程序理性，而為實體憲法裁判之理性奠基。當然現實上，大法官間互為主體之對話式論證過程可能受組織性之限制與考量等經驗事實之損害，例如大法官們可能會為了避免內部過度對立導致分裂，或為了湊足表決通過的多數而遷就、妥協，不再堅持以較佳之論證作為裁判之唯一基礎；大法官也可能因為來自民主立法部門以及公共領域之重大壓力，而畏於堅持憲法原則。司法違憲審查機關與民主立法部門之持續性憲法對話亦可能透露出權力爭鬥的氛圍；同樣可能的是，公共領域之發展待努力，尚不足以強力推動大法官與民主政治部門及公共領域間之法律對話

142 學者 András Sajó 亦採類似觀點。See András Sajó, *Constitutional Adjudication in Light of Discourse Theory*, in HABERMAS ON LAW AND DEMOCRACY: CRITICAL EXCHANGES 336, 366 (Michel Rosenfeld & Andrew Arato eds., 1998).

論辯。不僅如此，不同國家司法違憲審查實際實踐的情形亦存在高度差異。倘依接近上述這些對話論辯之預設條件的不同程度形成一光譜，美國與我國可以說即處於光譜之兩端；美國接近的程度遠非我國可比¹⁴³。不過，現實之運作與司法違憲審查過程所隱含之應然間的緊張正包含著調整改變的動機；換言之，經由對司法違憲審查相關程序制度與實踐之重構分析，所揭示之對話論辯結構，為現實之運作引進了改進的動力，從而吾人可以視理性之憲法裁判為一持續努力追求實現之計畫¹⁴⁴。

伍、結論

本文之核心問題是司法違憲審查中憲法解釋經常涉及準立法活動，如何可能獲致調和並同時確保法安定性與正確性（正義）之理性裁判？為此，本文首先批判性地探討Dworkin之法律解釋理論。Dworkin之建構解釋法企圖藉反思均衡方法而獲致健全之道德判

¹⁴³ 審查人之一指出違憲審查制度某些重要的差異，如具體／抽象與分散／集中式違憲審查制度之不同，對於違憲審查之程序理性具一定之影響。確實如此。關於具體／抽象法規審查在滿足論辯理論之程序條件要求的接近程度有所差異，已在註 140 有所討論。就分散／集中式違憲審查制度之差別而言，分散式違憲審查制度係由普通法院審理案件時附帶審查所適用之法規有無違憲，因此案件繫屬之各審級法院法官均得為違憲審查。從論辯理論觀之，在這種制度下上級審法院法官在作憲法裁判時，有義務必須審視下級審法院法官就系爭案件之見解並作回應。從而除了最高法院大法官間之對話論辯以外，更形成不同審級法院間另一重之對話論辯。不僅如此，遇爭議性之困難案件，下級審法院之裁判期間，尤其裁判作成後，必然已經引發廣泛之公共討論，不但有助於最高法院在審理前，案件相關爭議之不同面向、不同層次的問題點能得到一定程度的釐清，亦有可能促使大法官審理期間之公共討論更為擴散與深化。凡此，不僅擴展司法法律論辯之多重性，並可能產生加乘之積累效果。相對於此，這種對話論辯在集中式之違憲審查並不存在。據此，分散式較諸集中式顯然更接近理想之程序條件的要求。

¹⁴⁴ 重構分析具有批判之功能，see Habermas, *supra* note 122, at 260; Pedersen, *supra* note 122, at 465.

斷，以及調和既存法律實踐與對該實踐之最佳道德證立。本文指出此一理論途徑並不成功，而且反思均衡方法之獨白式取向更使問題為之惡化。

本文繼而討論Habermas之司法法律論辯理論。Habermas企圖從程序主義之理論途徑重新理解法安定性與裁判正確性（正義）概念、從而調和二者。Habermas強調司法裁判活動並非是法官個人獨白式之哲學反思，不能狹隘地僅限於對法體系進行解讀；反之，司法裁判必須踐行司法法律論辯之程序條件的要求，法官必須動態地、轉變性地調和裁判過程中多重、不同的觀點，才能調和法安定性與正確性（正義），從而確保裁判獲致實體理性之可能性。依此程序主義途徑，一方面，Habermas指出正確性是指為「好的理由」所支持之理性可接受性，這與Habermas之法安定性概念強調對於裁判「理由之非恣意性」的可期待性，恰相符應。另一方面，Habermas認為支持裁判正確性好的理由所構成的鍵子並無「自然的」終點，正義的追求是一恆具開放性之學習過程，個案裁判所建構之法律理論須保持其暫時性；亦即事實性與有效性間一直存在緊張關係。如此之裁判正確性的概念，也正能與其承認一定程度之法律不確定性的法安定性概念相調和。據此，Habermas從程序主義觀點重新理解法安定性與正確性概念，藉由司法法律論辯（亦即程序理性之實踐）而調和並同時確保了二者。本文之闡論司法違憲審查過程之程序理性基本上即立於此一理論之基礎上。

惟本文反對Habermas嚴格區分規範之證立與規範之適用的論點，而接受Habermas後來之理論修正，認此一區分實已相對化。尤其本文認為司法違憲審查雖是法官之裁判活動，但由於憲法基本權條款高度抽象、不確定，以及蘊含重大之基礎性哲學爭議，不可避免經常涉及準立法活動，且不同於民主立法決定可以廢棄一般司法裁判，憲法裁判則可以廢棄民主立法決定，從而必須在某種意義上為規範證立之論辯要素所補充。這意味違憲審查程序必須與民主政

治部門及公共領域有某種形式的連結，必須使民主政治部門及公共領域中相關憲法爭議之不同觀點能以某種方式影響憲法裁判，方足以確保司法違憲審查過程之程序理性。值得注意的是，由於本文對於法安定性與裁判正確性概念係從程序主義作理解，此種法安定性概念下仍保留一定程度之不確定性，正確性概念且具開放性與暫時性性質，故而司法違憲審查納入證立論辯要素，恰能與之相容。惟必須一提的是，違憲審查程序雖必須納入規範證立之論辯要素，但性質上主要仍是規範之適用，涉及的主要仍是適用論辯。其仍要求法官作為公正第三者之角色；法官－兩造當事人之三角結構式之對話論辯仍然保留。所納入之證立論辯要素僅居於補充地位。司法違憲審查所涉及之對話論辯，改變的只是由於涉及規範之證立，法律論辯之參與者不應限於案件當事人，相關憲法爭議之公共意見，法官並應有聽取、考量之義務。

本文並進一步對現代民主憲政國家之違憲審查程序進行重構，揭示違憲審查程序與民主政治部門及公共領域間存在之連結態樣，指出此一程序蘊含有大法官與民主政治部門及公共領域間三重密切相關（甚至相互重疊）之對話論辯結構。此外，本文並對職司憲法裁判之大法官的組成結構以及大法官評議以自由、平等方式進行等制度與實踐進行重構，指出其背後隱含大法官間之司法法律論辯接近「理想言說情境」此一溝通預設，從而確保了大法官對於多種不同觀點進行轉變性調和之公正性的可能性。

上述解釋分析之目的在於顯示司法違憲審查涉及多重之對話論辯，並不限於法官－兩造當事人此一三角結構式之論辯。而為此種多重法律論辯結構支配之司法違憲審查過程所蘊含之程序理性，即確保了憲法裁判實體內容更趨近於理性之可能性。藉此本文從多少內在於違憲審查制度及實踐的觀點，揭示了司法違憲審查過程尚待挖掘之程序理性，而為實體憲法裁判之理性奠基。

參考文獻

1. 中文部分

- Carl Schmitt著，川北洋太郎譯（1989），憲法の番人，東京：第一法規。[Schmitt, Carl (1985), *Der Hüter der Verfassung*, Berlin: Duncker & Humblot.]
- Ronald Dworkin著，李冠宜譯（2002），法律帝國，臺北：時英。[Dworkin, Ronald. 1986. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.]
- 王鵬翔（2004），論基本權的規範結構，臺大法學論叢，34卷2期，頁1-61。
- （2008），法律、融貫性與權威，政治與社會哲學評論，24期，頁23-68。
- 任冀平（1995），美國最高法院司法審查權的行使：理論與實際，歐美研究，25卷3期，頁45-93。
- 吳庚（2003），憲法的解釋與適用，臺北：自版。
- 李俊增（2007），對哈伯馬斯論辯倫理學中普遍化原則之證立的檢證——兼論此項原則之有效性的限度，收於：蔡英文、張福建編，現代性的政治反思，頁289-331，臺北：人文社會科學研究中心。
- （2012），程序主義與反思（身）法典範之爭：從哈伯馬斯對韋伯法理論之批判談起，歐美研究，42卷1期，頁83-165。
- 林遠澤（2003），意義理解與行動的規範性——試論對話倫理學的基本理念、形成與限度，人文及社會科學集刊，15卷3期，頁401-429。
- 翁岳生（2009），憲法之維護者——省思與期許（主題演說），收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務（六）（上冊），頁1-

169，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。

莊世同（2008），合法性與整全性——對德沃金法治觀的審視與反思，收於：王鵬翔編，2008法律思想與社會變遷，頁45-82，臺北：中央研究院法律研究所籌備處。

陳起行（2008），論網路時代以論述為基礎的公共理性，東吳法律學報，19卷4期，頁1-30。

湯德宗（2000），立法裁量之司法審查的憲法依據——違憲審查正當性理論初探，收於：權力分立新論，頁1-74，臺北：元照。

黃舒芃（2003），德國法上違憲審查權限爭議的歷史軌跡：從H. Kelsen與C. Schmitt的辯論談起，政治與社會哲學評論，5期，頁123-162。

——（2004），憲法解釋的「法適用」性格：從德國公法上法學方法論傳統對「法適用」與「法制訂」的區分探討聯邦憲法法院解釋活動的本質，政大法學評論，81期，頁51-107。

2. 外文部分

Alexander, Larry, and Ken Kress. 1997. Against Legal Principles. *Iowa Law Review* 82:739-796.

Alexy, Robert. 1993. Justification and Application of Norms. *Ratio Juris* 6:157-172.

———. 1998. Jürgen Habermas's Theory of Legal Discourse. Pp. 226-233 in *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges*, edited by Michel Rosenfeld and Andrew Arato. Berkeley, CA: University of California Press.

Balkin, Jack M. 2009. Framework Originalism and the Living Constitution. *Northwestern University Law Review* 103:549-614.

Baxter, Hugh. 2011. *Habermas: The Discourse Theory of Law and Democracy*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Brennan Jr., William J. 1989. Why Have a Bill of Rights?. *Oxford*

- Journal of Legal Studies* 9:425-440.
- Daniels, Norman. 1996. *Justice and Justification: Reflective Equilibrium in Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2003. Reflective Equilibrium. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://Plato.Stanford.edu/entries/reflective-equilibrium>.
- Dwars, Ingrid. 1992. Application Discourse and the Special Case-Thesis. *Ratio Juris* 5:67-78.
- Dworkin, Ronald. 1978. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . 1983. My Reply to Stanley Fish (and Walter Benn Michaels): Please Don't Talk about Objectivity Any More. Pp. 287-313 in *The Politics of Interpretation*, edited by W. J. T. Mitchell. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- . 1986. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- . 1996. *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . 2004. Replies to Critics. Pp. 339-395 in *Dworkin and His Critics: With Replies by Dworkin*, edited by Justine Burley. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- . 2006. *Justice in Robes*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- . 2011. *Justice for Hedgehogs*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Dyzenhaus, David. 1996. The Legitimacy of Legality. *University of Toronto Law Journal* 46:129-180.
- Fish, Stanley. 1983. Working on the Chain Gang: Interpretation in the Law and in Literary Criticism. Pp. 271-286 in *The Politics of Interpretation*, edited by W. J. T. Mitchell. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Fisher, Louis. 1988. *Constitutional Dialogues: Interpretation as Political Process*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Habermas, Jürgen. 1979. *Communication and the Evolution of Society*. Boston, MA: Beacon Press.
- . 1983. Interpretive Social Science v. Hermeneuticism. Pp. 251-269 in *Social Science as Moral Inquiry*, edited by Norma Haan, Robert N. Bellah, Paul Rabinow and William M. Sullivan. New York, NY: Columbia University Press.
- . 1990 (1983). Discourse Ethics: Notes on a Program of Philosophical Justification. Pp. 43-115 in *Moral Consciousness and Communicative Action*, translated by Christian Lenhart and Shierry Weber Nicholsen. Cambridge, MA: MIT Press.
- . 1996 (1992). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, translated by William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press.
- . 1997. *A Berlin Republic: Writings on Germany*. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
- . 1998. Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State. Pp. 203-236 in *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, edited by Ciaran P. Cronin and Pablo De Greiff. Cambridge, MA: MIT Press.
- Herzog, Don. 2012. Cute Prickly Critter with Presbyopia. *Michigan Law Review* 110:953-968.
- Ingram, David. 1995. *Reason, History and Politics: The Communitarian Grounds of Legitimation in Modern Age*. Albany, NY: State University of New York Press.
- . 2002. The Sirens of Pragmatism versus the Priests of Proceduralism: Habermas and American Legal Realism. Pp. 83-112 in *Habermas and Pragmatism*, edited by Mitchell Aboulafia, Myra Bookman and Catherine Kemp. New York, NY: Routledge.
- Marmor, Andrei. 1991. Coherence, Holism, and Interpretation: The

- Epistemic Foundations of Dworkin's Legal Theory. *Law and Philosophy* 10:383-412.
- McCarthy, Thomas. 1984. *The Critical Theory of Jürgen Habermas*. Cambridge: Polity Press.
- Michelman, Frank I. 1986. The Supreme Court 1985 Term – Foreword: Traces of Self-Government. *Harvard Law Review* 100:4-77.
- . 1999. *Brennan and Democracy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Pedersen, Jørgen. 2008. Habermas' Method: Rational Reconstruction. *Philosophy of the Social Sciences* 38:457-485.
- Post, Robert C., and Reva B. Siegel. 2007. Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash. *The Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* 42:373-433.
- Postema, Gerald J. 1987. "Protestant" Interpretation and Social Practices. *Laws and Philosophy* 6:283-319.
- . 2004. Integrity: Justice in Workclothes. Pp. 291-318 in *Dworkin and His Critics: With Replies by Dworkin*, edited by Justine Burley. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Raz, Joseph. 1994. *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*. New York, NY: Oxford University Press.
- Sajó, András. 1998. Constitutional Adjudication in Light of Discourse Theory. Pp. 336-370 in *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges*, edited by Michel Rosenfeld and Andrew Arato. Berkeley, CA: University of California Press.
- Schlink, Bernhard. 1998. The Dynamics of Constitutional Adjudication. Pp. 371-378 in *Habermas on Laws and Democracy*, edited by Michel Rosenfeld and Andrew Arato. Berkeley, CA: University of California Press.

- Shih, Wesley. 2003. Reconstruction Blues: A Critique of Habermasian Adjudicatory Theory. *Suffolk University Law Review* 36:331-390.
- Simmonds, Nigel E. 1987. Imperial Visions and Mundane Practices. *Cambridge Law Journal* 46:465-488.
- Smith, Dale. 2012. Law, Justice and the Unity of Value. *Oxford Journal of Legal Studies* 32:383-400.
- Solum, Lawrence B. 2010. The Unity of Interpretation. *Boston University Law Review* 90:551-578.
- Sunstein, Cass R. 1993. On Analogical Reasoning. *Harvard Law Review* 106:741-791.
- Sweet, Alec Stone. 2000. *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. New York, NY: Oxford University Press.
- Tushnet, Mark V. 1991. Critical Legal Studies: A Political History. *The Yale Law Journal* 100:1515-1544.
- Waldron, Jeremy. 2004. The Rule of Law as a Theater of Debate. Pp. 319-336 in *Dworkin and His Critics: With Replies by Dworkin*, edited by Justine Burley. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Wang, Peng-Hsiang (2007), Coherence and Revision- Critical Remarks on the Günther-Alexy-Debate, in: Agulió (Hrsg.), Logic Argumentation and Interpretation, ARSP Beiheft vol. 110, Stuttgart Steiner Verlag, S. 23-30.
- Zurn, Christopher F. 2007. *Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

On the Procedural Rationality of Constitutional Review:

A Shift from Dworkin's Monological Adjudication to Habermas's Judicial Legal Discourse

*Chuin-Zeng Lee**

Abstract

This article claims that constitutional review, while often engages in quasi-legislation, can achieve its rationality through Habermas's proceduralist approach. Whereas Dworkin's adjudicative theory aims to reconcile positive law and justice by way of Rawlsian reflective equilibrium, this article challenges Dworkin's monological approach and proposes that the rationality of adjudication be founded instead on a revision of Habermas's theory of judicial legal discourse, which also seeks to accommodate the needs for law's being both stable and just. To make possible that the discourses of justification are taken into due consideration in the course of constitutional review, this article argues for the relaxation of Habermas's sharp distinction between the discourses of justification and the discourses of application. With the help of such theoretical modification, this article maintains, the procedural rationality of constitutional review as embedded in the Habermasian multi-discourses therein, may serve to ensure the substantive rationality of constitutional adjudication.

KEYWORDS: judicial legal discourse, procedural rationality, constitutional review, constitutional interpretation, Habermas, Dworkin.

* Associate Professor, Department of Government and Law, National University of Kaohsiung.